

第一讲 刑法各论的概述

第一节 刑法各论与刑法总论的关系

(一)

1. 各论以总论的一般法则为基础来解释补充或者部分地修正总论的个别原理

刑法分则在具体罪名的原则上可能有所不同

Eg 1: 共同犯罪却为过失

(刑法总则) 共同犯罪：二人以上共同故意犯罪

(刑法分则) 交通肇事罪：其主观罪过是过失，原本是指驾驶员。但是当机动车所有人/承包人不在驾驶，驾驶员正常操作，但是根据但是机动车所有人/承包人的要求和命令超速行驶，发生交通事故。在本案中驾驶员要被定罪交通肇事，但是指使的机动车所有人/承包人则不需要(?) 所以最高院下达司法解释，如果机动车所有人/承包人指示/命令驾驶员违章驾驶，则按照交通肇事的共犯处理。而在此处，交通肇事明明是过失犯罪，却能被认定为“共同”犯罪，为共同过失。

此处，刑法各论的罪名个别地修正了总则。但是当然也是个别部分地修正，完全取决于刑法分则的特别规定和司法解释，不能用以推翻总论。

Eg 2: 一个行为定了数罪并罚

《刑法》第204条【骗取出口退税罪】第2款 纳税人缴纳税款后，采取前款规定的欺骗方法，骗取所缴纳的税款的，依照本法第二百零一条（逃税罪）的规定定罪处罚；骗取税款超过所缴纳的税款部分，依照前款的规定处罚。

(刑法分则) 此处骗取出口退税罪中，按照数罪并罚处理。

(刑法总则) 刑法禁止重复评价，一个行为只能定一个罪名原理。所以有想象竞合，从一重处罚。

2. 在处理具体犯罪时，总是只有与各个刑罚规定相结合，总论的一般原理才可能具有意义。

3. 在沿革上，刑法的总则性规定是从分则的各个犯罪规定中逐步产生（以欧洲刑法发展为例）

总论实际上是从分则各个规定中提炼出来的。比如英国最早的法律中有个故意杀人罪法、强奸罪法…一个罪名一个法律，后面才提炼出罪数形态问题、共同犯罪问题等等。

(二)

1. 方法——宰牛刀和屠龙术的选择问题

要在方法上选择宰牛刀，而不是屠龙术。需要指导具体实践，要学会对一个案件抽丝剥茧，要更加实务性。

2. 解释——以犯罪构成理论为基点，刑法体系性解释方法之提倡，兼及主观解释和客观解释的基本

必须对三阶层、四要件之一从一而终。

必须关注相关联罪名，体系性贯通。比如第226条诈骗罪和一系列诈骗类的犯罪（刑法第192-198条各种金融类诈骗、224条合同诈骗罪；没有写“诈骗”但是诈骗的使用假币罪，和诈骗有关的侵犯著作权等），所以刑法中涉及诈骗的罪名很多，要学会放在一起，区分这些诈骗。所以要多看罪名，多看法条和司法解释。

3. 任务——各种犯罪所固有的构成要件和处罚范围，同时还探讨各个构成要件之间的相互关系及其区别，关注法条及有效解释并做理论评析。

上课逻辑按照构成要件要素来说：行为主体——行为对象——行为本身——行为周边（行为时空条件、方式手段）——行为后果——行为与后果的因果关系——责任（主观罪过：故意/过失）——法定刑

（三）刑法修正案九以后的重要案例

较严重贪污犯罪一般判终生监禁，但是该案为数不多的使用了死刑立即执行。

【赖小明案】中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长。2021年1月5日，天津市第二中级人民法院公开宣判赖小民受贿贪污、重婚一案，对被告人赖小民以受贿罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币二百万元；以重婚罪，判处有期徒刑一年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

（基本案情）2008年至2018年，被告人赖小民利用担任原中国银行业监督管理委员会办公厅主任，中国华融资产管理公司党委副书记、总裁，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长兼华融湖河银行股份有限公司党委书记等职务上的便利，以及职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为有关单位和个人在获得融资、承揽工程、合作经营、调动工作以及职务提拔调整等事项上提供重大帮助，直接或通过特定关系人非法收受、索取相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17.88亿余元其中1.04亿余元尚未实际取得，属于犯罪未遂；2009年底至2018年1月，赖小民利用担任原中国华融资产管理公司党委副书记、总裁，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长兼华融湘江银行股份有限公司党委书记等职务上的便利，伙同特定关系人侵吞、套取单位公共资金共计人民币2513万余元；此外，赖小民在与妻子合法婚姻关系存续期间，还与他人长期以夫妻名义共同居住生活，并育有子女。天津市第二中级人民法院认为，被告人赖小民的行为构成受贿罪、贪污罪、重婚罪。赖小民受贿犯罪数额特别巨大，情节特别严重，主观恶性极深。在二十二起受贿犯罪事实中，有三起受贿犯罪数额分别在2亿元、4亿元、6亿元以上，另有六起受贿犯罪数额均在4000万元以上。同时，赖小民具有主动向他人索取贿赂和为他人职务调整、提拔提供帮助收受他人财物等从重处罚情节。赖小民在犯罪活动中，利用违规决定公司重大项目，越级插手具体项目，为他人谋取不正当利益，危国有金融企业负责人的职权，害国家金融安全和金融稳定，社会影响极其恶劣。赖小民目无法纪，极其贪婪，大部分犯罪行为均发生在党的十八大之后，属于典型的不收敛、不收手、顶风作案，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，社会危害极大，罪行极其严重，依法应予严惩。虽然赖小民提供下属人员重大犯罪线索并经查证属实，具有重大立功表现，但综合其所犯受贿罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，不足以对其从宽处罚。

需要思考的问题：

- （1）如何实现法条所承载的正义？
- （2）正义是否仅仅存在于法律条文中？
- （3）如何实现法条以外的正义？

· 此处，对于刑法分论的学习，需要注重“**法益**”概念对研究刑法分则的重要性。

比如，刑法中的诬告陷害罪，即捏造事实向司法机关告发意图使其受到惩罚。此处存在的问题是该罪名保护的法益是什么？观点一：保护的法益是公民的人身权益。观点二：司法秩序。观点三：人身权和司法秩序。观点四：人身权或者司法秩序。对于法益保护的理解不同，对于案件的认定就有不同。

第二节 刑法分则的体系

1. 犯罪的分类排列

十章：危害国家安全罪——危害公共安全罪——破坏社会主义市场经济秩序罪——侵犯公民人身权利、民主权利罪——侵犯财产罪——妨碍社会管理秩序罪——危害国防利益罪——贪污贿赂罪——渎职罪——军人违反职责罪

2. 犯罪分类排列的依据

① 原则上依据同类的法益

② 危害程度：大体上由重到轻——第一章死刑占比最高；第二章是针对不特定多数人；第三章比较特殊，是为了突出经济建设的重要性，所以仅此于第二章；第四章虽然可判到死刑的多，但是并非这样计算（比如经济犯罪死刑被废除，是一种进步，体现以人为本）

③ 犯罪之间的内在联系 比如120-126条主要就是讲恐怖主义、极端主义，只是根据不同的行为而做了区分

第三节 刑法分则规范的结构

“的”字结构，“处”…

（一）罪状

1. 罪状的概念：“的”字前面的内容

2. 罪状的种类：

（1）简单罪状：以高度抽象的语言进行描述。如第232条故意杀人罪，表述为“故意杀人者”。

（2）叙明罪状：非常详细地将行为人的所有构成要件要素全面的描述出来。如《刑法》第305条【伪证罪】在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。「“的”字之前规定了所有构成要件要素」

（3）引证罪状：（刑法条文与条文的关系）立法者为了防止刑法条文的重复，在描述一个罪状的时候，运用引用式的表述，去参照刑法中的其他条款。

《刑法》第115条【放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪】放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

【失火罪、过失决水罪、过失爆炸罪、过失投放危险物质罪、过失以危险方法危害公共安全罪】过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。”

（4）空白罪状：（刑法与其他法律的关系）在刑法当中对犯罪构成要件不做表述，而是去看前置法律的法律规范。

刑法是“保障法”的地位。比如数据安全法、网络安全法，而在刑法中如果要写相应罪名，作为保障法不可能将其全部罗列，所以会按照“违反…法”的句式来引用。

3. 其他表述：除了以上基本罪状之外，还有“加重、减轻”的表述，被称为 **加重罪状、减轻罪状**。

（二）法定刑

1. 法定刑的概念：“处”字后面的内容
2. 法定刑的种类：绝对确定的法定刑、绝对不确定的法定刑、相对确定的法定刑
在“除”之后会给司法者留下空间，在一个区间内进行裁判。
我们国家目前均为**相对确定法定刑**。

（三）关于罪名的问题（核心：罪名法定化）

1. 罪名的概念
2. 确定方式和种类

我国只由最高司法机关确定罪名。

（四）注意规定和法律拟制

1. 注意规定：一、并**不改变相关规定的内容**，只是对相关规定内容的**重申**，即使不设置注意规定，也存在相应的法律适用根据；二、**提示性**，其表述的内容与相关规定的内容完全相同）

这种重复是为了特殊条款的提示性。

《刑法》第156条规定了“走私共犯”，但是在第140-148条没有单独规定运输…假药劣药的共犯。156条即使删除也照样可以按照走私的共犯处理。而156条的作用是为了提示，提示的对象：（李翔）提示一般行为主体，恰恰排除司法人员；（张明楷）提示司法人员。

2. 法律拟制：将原本**不符合某种规定的行为也按照该规定处理**

《刑法》第289条【故意伤害罪、故意杀人罪、抢劫罪】聚众“打砸抢”，致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。毁坏或者抢走公私财物的，除判令退赔外，对首要分子，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

——抢劫罪属于占有型的财产犯罪，一定要用“非法占有”的目的。但是此处聚众“打砸抢”首要分子只是故意毁坏财物，没有非法占有目的。这样设置的原因只是因为抢劫罪比故意毁坏财物要重，对于特殊主体要特殊对待。

3. 区分注意规定与法律拟制的意义

讲课顺序：人身权利——财产权利——不特定的人身、财产权利犯罪

讲述结构：概述——司法解释——案例分析

解释逻辑：行为主体——行为对象——行为本身——行为周边（行为时空条件、方式手段）——行为后果——行为与后果的因果关系——责任（主观罪过：故意/过失）——法定刑

第二讲 侵犯公民人身权利、民主权利罪（第四章）

第一章 故意杀人罪

一、概述

第二百三十二条 【故意杀人罪】故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。

1. 概述：指故意非法剥夺他人生命的行为

2. 司法解释：

《关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》（失效/废止）

《关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释（二）》（失效/废止）

《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》

二、构成

1. 主体：一般主体

（1）结合《刑》第17条（总则） 年满十六周岁精神正常的为一般主体。

（2）在刑法修正案11之后，将故意杀人罪的年龄进一步下调至12-14周岁。但是12-14周岁设置了程序条件（最高人民检察院核准追诉）和实体条件（必须是情节恶劣）。

2. 行为：杀人（作为+不作为）

（1）不作为和作为都能构成杀人。不作为杀人指基于保证人地位未履行保证人义务，且行为结果和行为具有因果关系时。

（2）强调杀人的“非法性”，与合法的执行死刑加以区别。

（3）杀人的手段是多样化的，所以只要剥夺他人生命的行为即可认定为“杀人”

3. 对象：人（侵犯法益：**生命权**）

（1）故意杀人针对的是特定人

（2）对于人的认定：生命的开始和生命的终结

① 生命的开始：（通说·独立呼吸说）界定为**与母体的分离并且能够独立呼吸**。

【讨论·比较法】哪怕在西方国家政教合一情况下设立了堕胎罪，也并没有将堕胎罪和故意杀人等同——并没有将胎儿与人等同。

【实务界定·行为人将孕妇殴打至流产】甲在已知乙怀孕的情况下，将其殴打至流产，但是某鉴定机构认定乙为轻微伤，后想来华政鉴定，但是鉴定中心专家告知：接受过了鉴定，就无法二次鉴定了。所以后来就按照寻衅滋事定罪，但是此处存在问题，即保护的**法益被改变了——从人身权益变到了社会管理秩序**。

② 生命的终结：（通说·呼吸说）以**停止呼吸**作为生命终结的标准

【讨论】脑死亡

4. 罪责：故意（直接+间接）

对于杀人“故意”的司法认定——见故意伤害部分

三、认定故意杀人罪的关键词

1. “非法”、“他人”、罪数问题

2. 积极安乐死（属于“帮助自杀”问题）：

理论上存在争议，实践上做法不一。过去多认为都成犯罪，被害人对于生命的承诺和约定无效。

【讨论】消极安乐死 & 积极安乐死

3. 自杀

相约自杀、引起自杀（正当行为、错误行为以及违法行为、严重违法行为、犯罪行为）、教唆或者帮助自杀

①教唆或者帮助自杀：大陆法系将教唆或者帮助自杀独立出来作为独立罪名，这样仍然为将其犯罪化。但是目前我国有不将其认定为故意杀人，不做处理的变化。

教唆或帮助自杀不仅仅是一个法学问题，更是一个社会学问题。

②相约自杀不定罪，以欺骗相约自杀要定故意杀人罪。

③对于正当行为、错误行为引起的自杀不定罪 如老师口头批评学生学生去跳楼；但是对于严重的违法行为可能按照其他罪名定罪 如老师虐待学生学生去跳楼一般按照虐待相关罪名定罪；对于犯罪行为引起自杀则作为加重情节，法定刑升格。

4. 大义灭亲：认定为故意杀人罪，应由司法机关处理。

5. 处罚

处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。

第二章 故意伤害罪

一、概述

《刑》第234条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

故意伤害罪：指故意非法损害他人身体健康的行为

二、构成

1. 主体：一般主体

(1) 结合《刑》第17条（总则） 年满十六周岁精神正常的为一般主体。

(2) 已满14周岁不满16周岁的，故意伤害致人重伤或者死亡的需要负刑事责任。

(3) 在刑法修正案11之后，将故意伤害罪的年龄进一步下调至12-14周岁。但是12-14周岁设置了程序条件（最高人民检察院核准追诉）和实体条件（必须是情节恶劣）。

2. 行为：非法损害他人身体健康

在人身损害的司法鉴定中，将人身伤害鉴定分为各种标准（重伤、轻伤、轻微伤）在构成故意伤害罪时，必须达到轻伤以上的危害后果。

·（李翔：不提倡用重伤、轻伤、轻微伤划分鉴定标准，实现轻罪立法；可以分类，不要用“轻微、轻”这种价值评价；可以先在性质上作否定评价，入罪，后也有刑事和解等程序）

轻伤为一般的故意伤害，致人重伤或死亡为结果加重犯。

3. 对象：他人身体（侵犯法益：健康权）

4. 罪责：故意（直接+间接）

三、认定故意伤害罪的关键词

1. 非法损害他人身体

2. 对“他人”的理解——故意伤害胎儿行为的定性

故意伤害胎儿的行为有两种：①导致流产；②出生后由先天性损害。

【讨论·比较法】要保持体系化解释，比较法上将堕胎和故意杀人/伤害作出区分表明侵犯不同的法益，我国也同样不适宜用故意杀人/伤害罪来定罪。

【实务界定】实务中，有按照寻衅滋事罪处理的案例，但是在逻辑关系上这种处理不成立（保护的法益改变了）。

（当然解释的原理上）无法定罪。

（按照李翔老师的设想调整）调整故意伤害立法上的犯罪构成，设立轻罪和微罪上，就可以将这种行为纳入刑法保护范围。

3. 自伤行为

罪刑法定原则在立法上的要求就是自伤自残这种行为是不能作为犯罪行为对待的（禁止处罚不当法的行为「即不符合犯罪本质特点」）。

《刑》第434条【战时自伤罪】战时自伤身体，逃避军事义务的，处三年以下有期徒刑；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。「这种情况下，是对“自伤”作义务化处理，不能将其扩大化」

4. “同时伤害行为”问题研究

这种对于伤害自己的承诺无效（如欧洲中世纪的决斗）

5.（李翔）故意伤害罪的未遂不处罚，但是可以存在重伤未遂的可能（结果加重犯）。处罚。

| 【讨论】犯罪不成立 vs 犯罪未遂

没有达到犯罪要件，学界认为犯罪不成立。

（李翔）

盗窃罪三档“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。乙想盗窃一特定物数额为一万五千块，假定达到“数额巨大”标准，但他没有偷到。最高院司法解释行为人以数额巨大的财物为盗窃目标，没有盗窃成功，按照犯罪未遂处罚。但是按照「减轻未遂犯处罚原则」，对于未遂犯要么从轻要么减轻处罚，而“减轻”是在法定刑下一个量刑幅度内进行处罚。所以对于这个乙无论是从轻还是减轻，都是要受到处罚。

故意伤害罪重于盗窃罪（最先比较法定最高刑）。如果行为人以重伤作为犯罪故意的内容，但是没有伤害成功连轻伤都没有出现。那么我们应该按照未遂对其加以处罚。

这样就颠覆了“只要没有出现伤害结果就不定罪”的通说结论。

结论：轻伤时可以不定罪，但是可以存在重伤未遂且处罚。

前提：要有明确证据证明行为人重伤的故意。

6. 罪数（连续犯、同种数罪）与故意杀人罪的区别

【实务界定·角度】要从客观要素角度，考察全流程，评判行为人当时是杀人还是伤害。比如所用的器具是刀还是棍、刀的描述（长款、是否开刃）、是砍还是捅——危害程度不同。

【刘燕故意伤害案·母亲殴打儿子致死】2014年5月3日下午13时许，被告人刘燕因怀疑其子被害人高某某（男，2008年10月13日出生）偷拿家中的钱，遂在广东省潮州市潮安区果镇的出程屋内对高某某进行责问，因高某某不承认偷拿家中财物而心生气愤。刘燕叫高某某把衣服脱光，先用皮带抽打高某某。见高某某还不承认偷拿家中的钱，刘燕更加气愤，又持塑料管持续殴打高某某的头部、背部、四肢等部位致高某某全身多部位不同程度受伤，直至塑料管折断才停止。

当天下午16时许，高某某因被殴打受伤而出现身体不适的症状，刘燕遂将高某某送至医院抢救，经医生抢救发现高某某已死亡。医生遂向公安机关报警，刘燕于当天在医院内被公安民警带回审查。经查，高某某的死因符合全身体表广泛钝性暴力损伤造成创伤性、失血性休克联合心脏挫裂伤死亡。

（裁判结果）广东省潮州市潮安区人民检察院以被告人刘燕犯故意伤害言警提起公诉源潮州市潮安区人民法院经审理认为，被告人刘燕因怀疑儿子偷拿家中钱财而心生气愤，持械故意伤害自己的未成年人儿子；致其死亡，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘燕归案后如实供述自己的犯罪事实，且已获得其家属的谅解，依法予以从轻处罚。辩护人提出被告人刘燕的行为构成过失致人死亡罪，上述辩折意见据理不足，不予采纳。辩护人关于被告人具有坦白情节且取得家属谅解，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实性质，情节以及对社会的危害程度，依照刑法有关规定，判决被告人刘燕犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年。宣判后，没有上诉、抗诉判决已经发生法律效力。

意义：父母教育未成年子女过程中，因教育方式不当而心生气愤，并实施无节制的殴打未成年子女，致子女死亡的案件，属于典型的涉及家庭暴力刑事案件。

第三章 强奸罪

一、概述

《刑》第236条 【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。

【奸淫幼女罪】奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。

强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：

- (一) 强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
- (二) 强奸妇女、奸淫幼女多人的；
- (三) 在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
- (四) 二人以上轮奸的；
- (五) 奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
- (六) 致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

强奸罪：指使用暴力、胁迫或者其他手段，违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，或者奸淫不满14周岁的幼女的行为。

二、构成

1. 主体：一般主体

已满14周岁不满16周岁的也需承担刑事责任

【延伸】 奸淫幼女罪取消原因：解决刑法主体涵盖问题——八大罪包含强奸但是不包括奸淫幼女罪是不合理的

2. 行为：使用暴力、胁迫或者其他手段，**违背妇女意志**，强行与其发生性关系，或者奸淫不满14周岁的幼女

3. 对象：妇女、强奸幼女的对象是幼女

4. 罪责：**故意**

三、认定

(一) 普通强奸罪的认定

1. 保护法益：**妇女的性的自己决定权（性自由）**

进而认定核心为“**违背妇女意志**”。强调为行为发生时是否违背，而不是行为发生后反悔。

【讨论】妇女意志：不拒绝 or 没有明确同意

对于未成年人采用最严格的标准，对于成年女性有待讨论。

2. 对象：已满14周岁的妇女

【讨论】成年男性保护：对于成年男性没有保护，但不是完全不保护，可能评价为强制猥亵。

3. 暴力、胁迫或者其他手段的理解

(1) “暴力”：要能达到足以抑制被害人反抗的程度。具体判定上就是一定要有痕迹。

(2) “胁迫”：以暴力为内容胁迫或者精神上胁迫（如揭发隐私）。

(3) “其他手段”：除了暴力和胁迫以外任何让被害人处于不能、不知、不敢反抗的状态。其中对于这种状态的利用也属于，比如被害人深度醉酒（深度不是法律界定意义上的，是生理反应意义上的）。

附条件但是条件没有成就，也推定为违背妇女意志。比如妇女以给钱为前提的卖淫，行为人没有给钱，也会被推定为强奸。

4. 【讨论】丈夫能否成为强奸罪的主体的探讨

违背妇女意志是否因为婚姻关系而被否认，“奸淫”概念是否限于婚姻外，强奸罪侵犯的法益，实施婚姻内有无强奸。

（二）奸淫幼女——性侵害未成年犯罪罪名体系总结

- “明知”的认定
- 未成年人实施的行为
- 排除手段的暴力、胁迫或者其他手段
- 嫖宿幼女罪的废除

1. 性侵害未成年人犯罪罪名体系

- 强奸罪（奸淫幼女罪，已删除纳入强奸罪）
- 负有照顾职责人员性侵罪
- 强制猥亵、侮辱罪
- 猥亵儿童罪
- 组织卖淫罪
- 强迫卖淫罪
- 协助组织卖淫罪
- 引诱、容留、介绍卖淫罪
- 引诱幼女卖淫罪
- 嫖宿幼女罪（已删除纳入强奸罪）

【鲍毓明事件】2020年4月9日，媒体报道了山东杰瑞集团高管鲍毓明在长达近4年的时间里，非法拘禁，暴力性侵其14岁的养女小兰(化名)。

后最高检和公安部关于鲍某某涉嫌性侵案调查情况的通报，经全面深入调查，现有证据不能证实鲍某某的行为构成性侵犯罪。

【韩国N号房事件】

2. 法条变化及相关解释

法条修改情况

➤ 1979年刑法第139条 以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女，处三年以上十年以下有期徒刑。

奸淫不满十四周岁幼女的，以强奸罪论，从重处罚。

犯前两款罪，情节特别严重的或者致人重伤、死亡的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

二人以上犯强奸罪而共同轮奸的，从重处罚。

➤ 1997年刑法第236条 【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。

【奸淫幼女罪】奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。

强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：

（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；

- (二) 强奸妇女、奸淫幼女多人的；
- (三) 在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
- (四) 二人以上轮奸的；
- (五) 奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
- (六) 致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

➤ 两高两部《惩治性侵未成年人意见》：从严惩处的刑事政策面向

3. 需要研讨的问题

- (1) “强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣”的理解

注意：此处“情节恶劣”排除条文中已经列出的内容

- (2) “公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女”的理解

公共场所当众：除了行为人和相对人以外的**第三人在场，而且不考虑第三人是否看到**。

- (3) 如何理解“奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的”

| 是否包含精神伤害结果：倾向性在实务审查过程中偏向身体，但是目前越来越重视精神健康的保护。

(2023年) 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用 (三) .3

《解释》第3条第三项规定的对幼女身心健康造成其他伤害，**包括身体和精神心理的伤害**。创伤应激障碍、抑郁症等精神心理伤害往往是强奸案件中幼女被害人所遭受的一种主要伤害，**但鉴于精神心理伤害的鉴定及其与性侵害行为之间因果关系的判定更复杂和特殊，目前明确列举的条件尚不成熟，故仅作提示性规定，传递更加重视被害人精神心理健康的导向，具体留待实践把握**。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部近日联合发布的《关于办理性侵害未成年人刑事案件的意见》明确规定，应当全面收集能够证实未成年人被性侵害后心理状况或者行为表现的证据，未成年被害人出现心理创伤、精神抑郁或者自杀、自残等伤害后果的，应当及时检查、鉴定，该意见的施行，将为适用《解释》该项规定创造条件。

| **严格责任的司法适用**：此处“承诺”无效—推定为没有认知，采取严格责任（刑法家长主义），前提是行为人要明知。但是两高两院的司法解释中说明如果未满12周岁，直接推定行为人明知。

| 证据审查和适用问题：在证据中坚持适用统一标准，坚持事实基础。

4. 负有照顾职责人员性侵罪（刑法修正案十一）

《性侵意见》第21条 对于幼女负有特殊职责的人员与幼女发生性关系的，以强奸罪论处。对已满十四周岁的未成年女性负有特殊职责的人员，利用其优势地位或者被害人孤立无援的境地，迫使未成年被害人就范，而与其发生性关系，以强奸罪定罪处罚。

修法原理：从刑事政策的角度，强化行为人的主体义务。

(李翔)

- (1) 本罪保护的法益：未成年人（女性）身心健康
- (2) 不存在“违背被害人意志”的考量
- (3) 特殊主体：对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员

特殊职责的判定：不仅仅一定要具有形式上的职责，而是要从实质性的角度判断行为人对于被害人有没有优势或者支配地位。

目的：强化行为人的注意义务。

(4) 发生性关系的理解——是否一定是“性交”？（李翔）

对于236条，如果定成“性交”，只要没有发生性器官接触就不定罪。但是发生性行为的方式多样，如果不发生性器官的行为就会被定罪，法条就会被虚置。如果说猥亵，可是“猥亵”中一定要以违背意志为前提，而强奸罪没有这样的前提。所以并非其他种类的性行为就会被评价为强奸罪。

此外在该罪名中，叫做“性侵”而不是“强奸”的原因就是包含了和猥亵有关系的行为。

(5) 情节恶劣的理解

(6) 罪数问题

5. 强制猥亵、侮辱罪

(1) 行为主体和对象：均不限于男性女性

(2) 内容：满足行为人性心理的需求（倾向犯）

6. 猥亵儿童罪

(1) “情节恶劣”的理解

第四章 非法拘禁罪

一、概述

第二百三十八条 【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。

国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

1. 概述：指以非法拘禁或者以其他方法，非法剥夺他人人身自由的行为。

* 刑法中一旦规定有“非法”，就一定有对应的“合法性行为”。自由刑都是剥夺人身自由的，像管制是限制人身自由

* 剥夺权利必须依照法定程序。（观念：人生来自由平等）

2. 司法解释：

《关于对于索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》

《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》

二、构成

1. 主体：一般主体

年满16周岁，精神正常的人。

2. 行为：采用扣押或者其他方法，非法剥夺他人人身自由

(1) 方法：不论扣押的理由是否合法，只强调权利和程序。

只要客观上剥夺他人人身自由，就是非法拘禁。所以手段像故意杀人罪一样行为无法穷尽，举出典例“扣押”。

剥夺自由不是非要体现在暴力手段，对于被害人心理上实施强制力也属于。

(2) “自由”：对于被害人、加害人都认识到的现实具体人身自由。如果是一种未来的、可能的、抽象的自由，则不包括。比如在对方睡觉时候锁门，在对方醒之前打开门——如果对方没醒就是没有意识到，那这种自由是一种可能的，不是具体现实的，不能认定为非法拘禁；但是如果对方中途醒来，意识到自己被锁，就可以认定为非法拘禁。【实害犯】

人只要出生，就享有人身自由。

(3) 立案标准：累计24小时以上，如果有暴力则不受24小时限制。

（从“连续”24小时→“累计”24小时的调整）曾经发生【套路贷】案件，涉案律师寻找法律漏洞（我向你借钱，你用了某种方式，使得我以很少的本金背负了极高的债务）——借款合同、担保合同、抵押合同

① 从重处罚（侮辱、殴打行为）

② 结果加重犯（致人重伤、死亡的）

③ 转化犯（使用暴力致人重伤死亡的）

属于法律拟制，将不符合故意杀人时拟制为故意杀人/故意伤害罪。

【区别】犯意转化

如果构成非法拘禁罪，又产生了故意杀人/故意伤害的故意，则要非法拘禁和故意杀人/伤害数罪并罚。

【小结】出现非法拘禁致人重伤死亡的思路

[1]结果加重犯[2]转化犯[3]数罪并罚（犯意转化）

④ 主体身份从重（国家机关工作人员）

3. 对象：有现实的、具体的行动意思或者能力的人（侵犯法益：**现实自由**）

该对象标准根据侵害法益的现实自由说倒退可得。

4. 罪责：故意

【徐骏超等非法拘禁案——索债型非法拘禁的行为构成】

华东政法大学 法律学院 240101021016

第五章 绑架罪

一、概述

第二百三十九条【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

概述：指以勒索财物为目的绑架他人，或者处于政治性或者其他目的绑架他人作为人质，或者以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的行为

二、构成

1. 行为：以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的。

【联系】绑架罪与非法拘禁的关系

绑架罪与非法拘禁的关系：绑架罪中绑架的行为当然的包含了非法拘禁，但是绑架罪是一个重罪，其当然包含非法拘禁，所以对非法拘禁不再另行评价。（想象竞合，从一重处罚）

2. 对象：一般-他人；偷盗婴幼儿-婴幼儿

3. 罪责：故意

三、法定刑

《刑罚修正案（九）》对于绑架案的修改

➤ 修改前：以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。犯前款罪，致（说明主观罪过是过失）被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并没收财产

➤ 修改后：犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的处无期徒刑或者死刑，并没收财产。

只要是杀害被绑架人的，就不需要出现后面的致人重伤、死亡的情形¹，就选无期徒刑或死刑。伤害被绑架人的，需轻伤以上、故意，才可以选择无期徒刑或者死刑。（修改了罪制）

修改以前，只有“故意”杀人才能适用无期徒刑或者死刑。带来法律适用的难题。体系解释上有司法解释规定，故意伤害致被害人死亡可以处以十年以上、无期徒刑、死刑（故意的伤害、过失的杀人），最高是死刑。但是绑架致被绑架人死亡最高是无期徒刑。这是不合理的，因为这样比较下来，伤害致人死亡比绑架致人死亡危害性要高，存在问题。

¹ 【对比】参见《刑法学》（第七版），第478页谓：“‘杀害’应限于故意杀人既遂。”（张明楷）

四、案例对比

（一）背景—有指导性案例

【李飞故意杀人案】

（裁判要点-具有司法解释效力）对于因民间矛盾引发的故意杀人案件，被告人犯罪手段残忍，且系累犯，论罪应当判处死刑，但被告人亲属主动协助公安机关将其抓捕归案，并积极赔偿的，人民法院根据案件具体情节，从尽量化解社会矛盾角度考虑，可以依法判处被告人死刑，缓期二年执行，同时决定限制减刑。

（基本案情）2006年4月14日，被告人李飞因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，2008年1月2日刑满释放。2008年4月，经他人介绍李飞与被害人徐某某(女，殁年26岁)建立恋爱关系。同年8月，二人因经常吵架而分手。8月24日，当地公安机关到李飞的工作单位给李飞建立重点人档案时，其单位得知李飞曾因犯罪被判刑一事，并以此为由停止了李飞的工作李飞认为其被停止工作与徐某某有关。

（裁判结果）一审二审死刑立即执行，最高院发回重审（出于“限制死刑”的考虑），后死缓。

【王志才案】

（基本案情）同上，恋爱纠纷

（裁判结果）山东省潍坊市中级人民法院于2009年10月14日以(2009)潍刑一初字第35号刑事判决，认定被告人王志才犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。宣判后，王志才提出上诉。山东省高级人民法院于2010年6月18日以(2010)鲁刑四终字第2号刑事裁定，驳回上诉维持原判，并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院根据复核确认的事实，以(2010)刑三复22651920号刑事裁定，不核准被告人王志才死刑，发回山东省高级人民法院重新审判。山东省高级人民法院经依法重新审理，于2011年5月3日作出(2010)鲁刑四终字第2-1号刑事判决，以故意杀人罪改判被告人王志才死刑，缓期二年执行剥夺政治权利终身，同时决定对其限制减刑。

（裁判结果）一审二审死刑立即执行，最高院发回重审，后死缓。

（二）现在案例

【忻元龙绑架案】

（基本案情）绑架勒索，绑架小孩勒索家长。一绑架即杀害，后勒索。打勒索电话不断变化地点。

（诉讼过程）死刑→死缓两年→再上诉改判

（裁判结果）一审死刑；被告人上诉浙江高院死缓；（提抗）浙江省人民检察院审查确有错误。

浙江省人民检察院经审查认为，浙江省高级人民法院二审判决改判忻元龙死刑缓期二年执行确有错误，于2007年8月10日提请最高人民检察院按照审判监督程序提出抗诉。最高人民检察院派员到浙江专门核对了案件相关情况。最高人民检察院检察委员会两次审议了该案，认为被告人忻元龙绑架犯罪事实清楚，证据确实、充分依法应当判处死刑立即执行，浙江省高级人民法院以“鉴于本案具体情况”为由改判忻元龙死刑缓期二年执行确有错误，应予纠正。理由如下：

一、事实清楚

二、浙江省高级人民法院二审判决确有错误。二审改判是认为本案证据存在两个疑点。一是卖给忻元龙波导1220型手机的证人傅世红在证言中讲该手机的串号与公安人员扣押在案手机

的串号不一致，手机的同一性存有疑问；二是证人宋丽娟和艾力买买提尼牙子证实，在案发当天看见一中年妇女将一个与被害人特征相近的小女孩带走，不能排除有他人作案的可能。经审查，这两个疑点均能够排除。一是关于手机同一性问题。

经审查，公安人员在询问傅世红时，将波导1220型手机原机主洪义军的身份证号码误记为手机的串号。宁波市人民检察院移送给宁波市中级人民法院的《随案移送物品文件清单》中写明波导1220型手机的串号是350974114389275，且洪义军将手机卖给傅世红的《旧货交易凭证》等证据，清楚地证明了从忻元龙身上扣押的手机即是索要赎金时使用的手机，且手机就在宁波市中级人民法院，专机同一性的疑点能够排除。二是关于是否存在中年妇女作案问题。

艾力买买提尼牙子证言证明的案卷原有证据能够证实宋丽娟“带中年妇女带走小女孩买买提尼”是木姿轰药，宏照织，蔬踢柔蜀提忌。始本案无子证言证明的市年妇女与忻元龙绑架杨某某并非同一地点左右，艾力买买提尼牙子说你吸会f竟证明的是迪欧咖啡厅南边的电脑培训学校门口，不207号限限忻元施绑架的地点；宋丽娟证言证明的中年妇女带走小女孩的地约场，因为宋丽娟所比

三、忻元龙所犯罪行极其严重，对其应当判处死刑立即执行。一是忻元龙精心预谋犯罪、主观恶性极深。忻元龙为实施绑架犯罪进行了精心预谋，多次到慈溪市“踩点”，并选择了相对僻静无人的地方作为行车路线。忻元龙以“陈老师找你”为由将杨某某骗上车实施绑架，与慈溪市老年大学剑桥英语培训班负责人陈老师的姓氏相符。

忻元龙居住在宁波市的鄞州区，选择在宁波市的慈溪市实施绑架，选择在宁波市的北仑区杀害被害人，之后又精心实施勒索赎金行为，赴安徽省广德县购买波导1220型手机，使用异地购买的手机卡，赴安徽省宣城市、芜湖市打勒索电话并要求被害人父亲到浙江省长兴县交付赎金。二是忻元龙犯罪后果极其严重、社会危害性极大。忻元龙实施绑架犯罪后，为使自己的罪行不被发现，在得到被害人家庭信息后，当天就将年仅9岁的杨某某杀害，并烧掉了杨某某的书包，扔掉了杨某某挣扎时脱落的鞋子，实施了毁灭罪证的行为。

忻元龙归案后认罪态度差。开始不供述犯罪，并隐瞒作案所用手机的来源，后来虽供述犯罪，但编造他人参与共同作案。忻元龙的犯罪行为不仅剥夺了被害人的生命、给被害人家属造成了无法弥补的巨大痛苦，也严重影响了当地群众的安全感。三是二审改判忻元龙死刑缓期二年执行不被被害人家属和当地群众接受。被害人家属强烈要求判处忻元龙死刑立即执行，当地群众对二审改判忻元龙死刑缓期二年执行亦难以接受，要求司法机关严惩忻元龙。

· 最高院令重申，浙江省最高院判死刑

第六章 拐卖妇女、儿童罪

【对向犯（对行性犯罪）】

立法上对于对向犯的立法模式（基于形式政策的考量）：（1）彼此异罪（2）彼此同罪

（3）行为之间互为对象，但是将其中一种行为作为犯罪，另一种行为认定为违法 卖淫嫖娼中，组织卖淫按照犯罪处理（4）只将一种行为作为犯罪评价，另一种不做法律评价 出卖和购买侵权复制品

一、概述

1. 概述：指以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送或者中转妇女、儿童以及偷盗婴幼儿。

2. 司法解释

《关于审理拐卖妇女案件适用法律若干问题的解释》

3. 历史变化

1979年《刑法》规定「拐卖人口罪」，法定最高刑只有15年。1983年9月2日《关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》补充规定可以在法定刑以上定罪，甚至判处死刑。

1997年研制时取消了拐卖人口罪，但是以《决定》为蓝本，在《刑法》第240条规定了「拐卖妇女、儿童罪」。

二、构成

1. 主体：一般主体

2. 行为：拐卖：（核心：帮助行为按照实行行为来定）以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转行为之一的。

① 核心：只要有**出卖的目的**，就要被认定为拐卖

② 行为上，**帮助行为按照实行行为来定**。“拐卖”是包含拐卖的很多行为

3. 对象（特定性）：妇女儿童（侵害法益：被拐卖者在**本来生活状态下的身体安全与行动自由**）

包括外国国籍与无国籍的妇女与儿童；

包括真两性畸形人和女性假两性畸形人。

【讨论】已满14周岁的男性公民（？）

回到刑法的立法目的和立法根据上，（第一条）立法是根据宪法和司法实践。在司法实践中没有一起拐卖男子回家当老公的，所以基于实践没有必要这样立法。但是不意味着拐卖男子不成立犯罪，因为这过程中限制了人身自由，所以可以定非法拘禁、强迫劳动罪等。

4. 罪责：故意—以出卖为目的

三、加重处罚情节

1. 拐卖妇女、儿童集团的首要分子

2. 拐卖妇女、儿童三人以上的

将拐卖设定为包容犯：

3. 奸淫被拐卖的妇女的——处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑

用拐卖妇女、儿童罪包容强奸罪（因此，强奸罪既然可以被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，那么拐卖妇女、儿童罪需升格到死刑）

4. 诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的

包容强迫卖淫罪

5. 以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的
6. 以出卖为目的，偷盗婴幼儿的
7. 造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的
8. 将妇女、儿童卖往境外的

华东政法大学 法律学院 24010102016

第七章 收买被拐卖的妇女、儿童罪

一、概述

《刑法》第241条 【收买被拐卖的妇女、儿童罪】 收买被拐卖的妇女、儿童的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚。

收买被拐卖的妇女、儿童，非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等犯罪行为的，依照本法的有关规定定罪处罚。

收买被拐卖的妇女、儿童，并有第二款、第三款规定的犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。

1. 概述：故意收买被拐卖的妇女、儿童的行为

2. 历史变化

1979年《刑法》没有相关规定。1983年9月2日《关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》对其严惩。

1997年在《刑法》第241条规定了「拐卖妇女、儿童罪」，法定最高刑为三年，其中特别规定了情节不严重的不构成犯罪。

2015《刑法修正案（九）》将本条第6款修改为对于儿童“从轻处罚”，对于妇女“从轻或者减轻处罚”。（删除了原文规定的“可以不追究刑事责任”）

（【对比】拐卖起刑点就是三年）

【讨论】将收买和拐卖妇女、儿童罪同罪同罚

之所以区别，因为在收买被拐卖的妇女、儿童罪中，采取了数罪并罚的立法模式。所以当出现“被拐卖后被拐卖者满意”的情况时，设置较低的法定刑，表明一方面法律对于“人作为商品”的否定评价，另一方面承认实践中不存在不违背意志的买卖存在不违背意志的收买。剩下的问题是社会治理的问题。

【延伸】法律的运行有非常特殊的背景，法律的适用不能非常机械性的适用，要根据司法实践、结合情理。

法定刑的抬高不是解决问题的根本方式，要跳出“治罪”的思维，转向“治理”的思维——许多问题是社会治理的问题。刑法只是社会治理的一小部分。（并不是法定刑抬高，就能天下大同了）

所以要关注社会案件，更要看案件的事实本身，理性看待社会犯罪问题——正义是双向的。

二、构成

1. 主体

2. 行为：收买：行为人用金钱或者其他财物，作为被拐卖的妇女、儿童的身价，使妇女、儿童处于自己的支配之下。

3. 对象：被拐卖的妇女、儿童

4. 罪责：故意（明所知收买的妇女、儿童是被他人拐卖的+明知自己的收买行为侵犯了妇女、儿童的人身权利）

* 如果行为人主观上具有出卖的目的而收买一定拐卖妇女、儿童罪

第八章 诬告陷害罪

一、概述

1. 概述：捏造犯罪事实，向国家机关或者有关单位虚假告发，意图使他人受到刑事追究，情节严重的行为。

二、构成

1. 行为：捏造犯罪事实、虚假告发的行为

2. 对象：他人（特定自然人）

从重处罚：国家机关工作人员

(1) 该罪针对的是具体特定的人，而不是某种现象

(2) 如果对象是「单位」，其主管人员也可能有可能因此受到刑事追究，所以成立诬告陷害。

3. 罪责：故意——意图使他人受到刑事追究

* 错告或者检举失实（没有“**让他人受到刑事追究**”的主观故意）——无罪
而此处的主观故意很难认定。

【区别】诽谤罪

诬告陷害罪是有可能使他人受到刑事追究的犯罪行为。

【讨论】如何正当看待举报权，以及诬告陷害

对于“一张纸就能改变一个人的人生”的现象，刑法需要进行评价，因为「事实」非常重要。

（典型案例）典型意义：提升司法公信力不仅要求司法案件的结果公正，也要求司法人员的形象符合中立、公正的客观标准。司法人员的社会声誉是司法机关公正形象的重要载体，恶意贬损法官形象就是诋毁司法公信。当事人对裁判结果或者法院工作人员司法作风不满，可以通过上诉、申请再审、信访投诉举报等多种合法途径反映情况、表达诉求，但决不能毫无根据地随意指责司法人员贪腐或有其他犯罪行为。没有确凿证据，甚至故意捏造事实、散布谣言，轻易对法官、审判辅助人员提出性质严重的指控，不仅是对法院工作人员的人格污蔑，也是对司法公信的恶意破坏，更是对社会公共利益的肆意侵犯。《办法》第十三条规定，法官因依法履职遭受不实举报、诬告陷害致使名誉受到损害的，其所在人民法院应当会同有关部门及时澄清事实，消除不良影响，维护法官良好声誉，并依法追究相关单位或者个人的责任。本案中，宋某故意捏造事实、进行虚假告发，导致有关单位对相关人员进行调查，给司法人员工作造成巨大压力、正常生活受到严重影响。法院依法对其判处刑罚，不仅是对法院干警的关心爱护，也是为司法人员依法履职提供制度保障的必要举措。

第九章 强迫劳动罪

一、概述

概述：指以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的行为。

二、构成

- 行为：以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动
- 对象：他人
- 罪责：故意

第十章 雇佣童工从事危重劳动罪

一、概述

概述：违反劳动管理法规，雇佣未满十六周岁的未成年人从事超强度体力劳动或从事高空、井下作业或在爆炸性、易燃性、放射性、毒害性等危险环境下从事劳动的行为。

二、构成

- 主体：一般主体
- 行为：雇佣未满十六周岁的未成年人从事超强度体力劳动或在上述危险环境下从事劳动

第二百四十六条 【侮辱罪；诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。

通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

第十一章 侮辱罪

一、概述

1. 概述：指以暴力或者其他方法，公然贬低、损害他人人格，破坏他人声誉，情节严重的行为。

2. 司法解释

《关于〈中华人民共和国刑法修正案（九）〉时间效力问题的解释》

《关于维护互联网安全的决定》

《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

二、构成

第十二章 诽谤罪

一、概述

1. 概述：故意捏造并散布虚构的事实，损害他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。

2. 司法解释

《关于〈中华人民共和国刑法修正案（九）〉时间效力问题的解释》

《关于维护互联网安全的决定》

《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

二、构成

1. 行为：捏造并散布虚构的事实，损害他人人格，破坏他人名誉

2. 对象：他人（特定、确定的人）（侵犯法益：**他人人格和名誉**）

3. 罪责：故意—具有损害他人人格、破坏他人名誉的目的

【区别】诬告陷害罪

诽谤罪内容更加宽泛，因为诬告陷害罪必须捏造的是“犯罪事实”

侮辱、诽谤罪司法解释

(1) 【延伸】侮辱、诽谤罪属于传统犯罪的网络化

(2) 司法解释

【法释〔2013〕21号】最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释（2013年9月5日最高人民法院审判委员会第1589次会议，

2013年9月2日最高人民法院第12届检察委员会第9次会议通过，2013年9月10日公布，2013年9月10日起施行

第一条 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“捏造事实诽谤他人”：

（一）捏造损害他人名誉的事实，在信息网络上散布，或者组织、指使人员在信息网络上散布的；

（二）将信息网络上涉及他人的原始信息内容篡改为损害他人名誉的事实，在信息网络上散布，或者组织、指示人员在信息网络上散布的；

明知是捏造的损害他人名誉的事实，在信息网络上散布，情节恶劣，以“捏造事实诽谤他人”论。

①行为：“散布”可以被认定；如果是“捏造”，则不用强调特意散布，因为其本身就包含“散布”

②“明知”：确知；可能明知：确知可能是（确知可能是可能不是）实践中“以为是”免责声明”，实际上确认了行为人的“确知可能是”的状态。

第二条 利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”：

（一）同一诽谤信息实际被点击、浏览此处达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的；

（二）造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的；

（三）二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的；

（四）其他情节严重的情形

①客观处罚条件：行为结束后，如何确定罪就不受行为人自己控制了。

②【讨论】责任分配问题：过程中转发人的责任如何分配

第三条 利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第二款规定的“严重危害社会秩序和国家利益”

（一）引发群体性事件的；

（二）引发公共秩序混乱的；

（三）引发民族、宗教冲突的；

（四）诽谤多人，造成恶劣社会影响的；

（五）损害国家形象，严重危害国家利益的；

（六）造成恶劣国际影响的；

（七）其他严重危害社会秩序和国家利益的情形。

①虽然“侮辱诽谤罪”告诉才处理，但是存在例外规定“严重危害社会秩序和国家利益”——自诉变公诉

理由：当下互联网的发达使得被害人找到证据难度变高，“告诉才处理”被虚化。《刑法修正案（九）》对侮辱、诽谤罪修改后，增加“通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。”

②对“损害国家形象，严重危害国家利益”不能任意扩大解释。比如一男子发布家乡征地情况，当地招商局不能以损害招商信息，进而损害国家利益为由判其犯罪。

第四条 一年内多次实施利用信息网络诽谤他人行为未经处理，诽谤信息实际被点击、浏览、转发次数累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。

【邱厚光、梁惠荣侮辱、诽谤案】

华东政法大学 法律学院 24010102016

第十三章 刑讯逼供罪

一、概述

第二百四十七条 【刑讯逼供罪；暴力取证罪】司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的，处三年以下有期徒刑或者拘役。致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪从重处罚。

概述：司法工作人员对犯罪嫌疑人，被告人实行刑讯逼供的行为。

二、构成

1. 主体：司法工作人员
2. 行为：刑讯逼供
3. 对象：嫌疑人、被告人
4. 罪责：故意

第十四章 侵犯公民人身权利的其他犯罪

- 过失致人重伤罪
- 妨碍公务罪
- 聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童罪
- 非法搜查罪
- 非法侵入住宅罪
- 暴力取证罪
- 虐待被监管人员罪（转化犯问题：如果虐待行为导致被监管人重伤或者死亡，将转化为故意伤害/杀人罪）

华东政法大学 法律学院 240101021016

第十五章 民主权利的保护（仅了解）

- 煽动民族仇恨、民族歧视罪（情节严重）
- 出版歧视、侮辱少数民族作品罪（情节恶劣，造成严重后果）
- 非法剥夺公民宗教信仰自由罪（国家机关工作人员，情节严重）
- 侵犯少数民族风俗习惯罪（国家机关工作人员，情节严重）
- 侵犯通信自由罪（情节严重）
- 私自开拆、隐匿、弃毁邮件、电报罪（邮政工作人员，转化为盗窃罪的情形：“犯前款罪而窃取财物的，依照本法第二百六十四条的规定定罪从重处罚。”）

华东政法大学 法律学院 240101021016

第十六章 侵犯公民个人信息罪

一、概述

第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。

窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。

单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。

1. 概述：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的行为。

2. 司法解释

《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》

3. 历史沿革

2015年11月1日，《刑法修正案（九）》讲“出售、非法提供公民个人信息罪”和“非法获取公民个人信息罪”整合为“侵犯公民个人信息罪”。

二、构成

1. 主体：包括单位

2. 对象（侵犯法益：**保护背后公民的人身权利**）

3. 行为：出售、提供公民个人信息

4. 罪责：故意

三、有关司法解释

【法释〔2017〕10号】最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释（2017年3月20日最高人民法院审判委员会第1712次会议、2017年4月26日最高人民检察院第12届检察委员会第63次会议通过，2017年5月8日印发，2017年6月1日起施行）

第一条 刑法第253条之一规定的“**公民个人信息**”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。

第二条 违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的，应当认定为刑法第253条之一规定的“违反国家有关规定”。

其他罪名都是“违反国家规定”，指的是“违反法律、行政法规”。此罪多出一个“违反部门规章”，加强有关公民信息保护。

第三条 向特定人提供公民个人信息，以及通过信息网络或者其他途径发布公民个人信息的，应当认定为刑法第253条之一规定的“提供公民个人信息”。

未经被收集者同意，将合法收集的公民个人信息向他人提供的，属于刑法第253条之一规定的“提供公民个人信息”，但是经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。

第四条 违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第253条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。

第五条 非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第253条之一规定的“情节严重”：

（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；行为人将行踪轨迹提供给别人 其行为就已经结束；后是否定罪完全取决于他人是否用于犯罪（客观处罚条件）

（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪（不要求具体。如果具体，那么构成该罪和所犯罪的帮助犯的想象竞合），向其出售或者提供的；

（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息5条以上的；（敏感信息中的敏感）

（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息500条以上的；（敏感信息）

（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息5000条以上的；信息倍数可以换算使用。比如侵犯了30条三项中的+200条四项中的，构成犯罪

（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；

（七）违法所得5000元以上的；

（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；

（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者2年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；

（十）其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第253条之一第一款规定的“情节特别严重”：

（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；

（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；

（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准10倍以上的；

（四）其他情节特别严重的情形。

不能认定“情节严重”时，可能构成民法上的侵权。

此处的“情节严重”是定罪情节，而这些定罪情节不能二次评价用于量刑。

第六条 为合法经营活动而非法购买、收受本解释第5条第一款第三项、第四项规定以外的公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第253条之一规定的“情节严重”：

（一）利用非法购买、收受的公民个人信息获利5万元以上的；

（二）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者2年内受过行政处罚，又非法购买、收受公民个人信息的；

（三）其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为，将购买、收受的公民个人信息非法出售或者提供的，定罪量刑标准适用本解释第5条的规定。

第七条 单位犯刑法第253条之一规定之罪的，依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚，并对单位判处罚金。

第八条 设立用于实施非法获取、出售或者提供公民个人信息违法犯罪活动的网站、通讯群组，情节严重的，应当依照刑法第287条之一的规定，以非法利用信息网络罪定罪处罚；同时构成侵犯公民个人信息罪的，依照侵犯公民个人信息罪定罪处罚。

第九条 网络服务提供者拒不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，致使用户的公民个人信息泄露，造成严重后果的，应当依照刑法第286条之一的规定，以拒不履行信息网络安全管理义务罪定罪处罚。

第十条 实施侵犯公民个人信息犯罪，不属于“情节特别严重”，行为人系初犯，全部退赃，并确有悔罪表现的，可以认定为情节轻微，不起诉或者免于刑事处罚；确有必要判处刑罚的，应当从宽处罚。

第十一条 非法获取公民个人信息后又出售或者提供的，公民个人信息的条数不重复计算。向不同单位或者个人分别出售、提供同一公民个人信息的，公民个人信息的条数累计计算。对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。

第十二条 对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的1倍以上5倍以下。

四、《刑法修正案（九）》对侵犯公民个人信息罪的修改

· 修改前:国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

· 修改后:违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。

· 修改前:窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款规定处罚。

· 修改后:窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，依照第一款的规定处罚。

第十七章 报复陷害罪

一、概述

第二百五十四条 【报复陷害罪】国家机关工作人员滥用职权、假公济私，对控告人、申诉人、批评人、举报人实行报复陷害的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处二年以上七年以下有期徒刑。

1. 概述：是指国家机关工作人员滥用职权、假公济私，对控告人、申诉人、批评人、举报人实施报复陷害的行为。

2. 司法解释

《关于渎职侵犯犯罪案件立案标准的规定》

二、构成

1. 主体：国家机关工作人员

2. 行为：滥用职权、假公济私对控告人、申诉人、批评人、举报人实施报复陷害的行为。

(1) **立案标准**：最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》（1999.9.9高检发释字[1999]2号）》

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

（一）致使被害人的人身权利、民主权利或者其他合法权益受到严重损害的；

（二）致人精神失常或自杀的；

（三）手段恶劣、后果严重的。

（2）价值观：将公权力关在笼子里。

3. 对象：控告人、申诉人、批评人、举报人（侵害法益：**公民人身权利和民主权利**；行为人本人对于国家机关赋予权力的滥用「类似渎职」）

第十八章 破坏选举罪

一、概述

第二百五十六条 【破坏选举罪】在选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员时，以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等手段破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者剥夺政治权利。

1. 概述：在选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员时，以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等手段破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权。

·（李翔）应该将破坏选举罪扩大到村民委员会和居民委员会中。因为这是最基层的东西，往往地方村民/居民委员会的破坏选举现象非常多。

2. 司法解释

《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》

第十九章 暴力干涉婚姻自由罪

一、概述

第二百五十七条 【暴力干涉婚姻自由罪】以暴力干涉他人婚姻自由的，处二年以下有期徒刑或者拘役。

犯前款罪，致使被害人死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。

第一款罪，告诉的才处理。

概述：以暴力干涉他人婚姻自由的行为

二、构成

1. 行为：暴力干涉他人婚姻自由
2. 对象：他人（侵害法益：婚姻自由）
3. 罪责：故意

第二十章 重婚罪

一、概述

第二百五十八条 【重婚罪】有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。

概述：有配偶而重婚，或明知他人有配偶而与之结婚的行为

二、注意事项

1. 一夫一妻制
2. 法律婚和事实婚
 - 法律婚：经过法律登记
 - 事实婚：没有法律登记，但是以夫妻名义公开生活。

* 民法上不承认事实婚。但是在刑法上仍然认可事实婚姻，即有事实婚的照样定重婚罪。而且现在也不可能

3. 法律标准
4. 重婚者和相婚者

第二十一章 破坏军婚罪

第二百五十九条 【破坏军婚罪】明知是现役军人的配偶而与之同居或者结婚的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

（**注意规定**——不说也会定强奸罪—提示社会公民）利用职权、从属关系，以胁迫手段奸淫现役军人的妻子的，依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚。

第二十二章 虐待罪

一、概述

1. 概述：虐待家庭成员，情节恶劣的行为

2. 司法解释

《关于〈中华人民共和国刑法修正案（九）〉时间效力问题的解释》

二、注意

· 情节恶劣的认定：（1）虐待行为持续的时间（2）虐待行为的次数（3）虐待的手段（4）虐待的后果是否严重

· 【区别】与故意杀人罪和故意伤害罪的区别

看是否有伤害和杀人的故意。

三、《刑法修正案（九）》对虐待罪的修改

· 修改前（第三款）：第一款罪，告诉的才处理。

· 修改后（第三款）：第一款罪，告诉的才处理，但被害人没有能力告诉，或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。

第二十三章 虐待被监护、看护人罪

《刑法修正案（九）》新增罪名

一、概述

第二百六十条之一【虐待被监护、看护人罪】对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人，情节恶劣的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有第一款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、构成

1. 主体：对未成年人、老年人、患病的人、残疾的人负有监护、看护职责的人。

2. 对象：未成年人、老年人、患病的人、残疾的人

第二十四章 遗弃罪

一、概述

第二百六十一条【遗弃罪】对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

概述：对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。

二、构成

第二百六十一条 【遗弃罪】对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

1. 主体：对年老、年幼、患病或者没有独立生活能力的人，负有扶养义务的人

注意：不限于家庭成员

2. 行为：拒绝扶养，情节严重

3. 对象：年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人

三、注意

与虐待罪、故意杀人罪、故意伤害罪的界限

第二十五章 拐骗儿童罪

一、概述

第二百六十二条 【拐骗儿童罪】拐骗不满十四周岁的未成年人，脱离家庭或者监护人的，处五年以下有期徒刑或者拘役。

* 不是卖，没有出卖的目的，否则适用另一罪名

第二十六章 组织残疾人、儿童乞讨罪

一、概述

第二百六十二条之一 【组织残疾人、儿童乞讨罪】以暴力、胁迫手段组织残疾人或者不满十四周岁的未成年人乞讨的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

概述：以暴力、胁迫手段组织残疾人或者不满十四周岁的未成年人乞讨的行为

第二十七章 组织未成年人进行违反治安管理活动罪

一、概述

第二百六十二条之二 【组织未成年人进行违反治安管理活动罪】组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

概述：组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的行为。

第三讲 侵犯财产罪（第五章）★

罪名一览

需要思考的问题

- 以不法手段取回或者夺回自己所有而又由他人占有的财务，如何处理？
- 第三者窃取或者骗取他人无权占有的赃物或者违禁品时，是否构成犯罪？
- 嫖娼者在实施嫖娼行为后，欺骗卖淫者，使其免受嫖娼费用的，是否构成诈骗罪？
- 债权人使用胁迫手段实现自己债权的行为，是否构成敲诈勒索罪？
- 甲欲向公务人员乙行贿，委托丙将2万元交给乙，丙将2万元据为己有时，是否构成侵占罪？

——以上为题的研究都需要解决财产犯罪的共性问题，尤其是法益问题。

关于本罪的法益：财产所有权及其他本权（如占有，也需要被保护）

关于财产侵犯罪的对象问题↓

关于“财物”的内涵和外延

- 财物是否限于有体物？不限。无体物比如煤气
 - 财物是否仅限于有价值之物？不限。判断“有价值”是从法律上评价，比如淫秽物品、毒品等。但是此处不限于有价值之物，比如盗窃淫秽物品也构成盗窃。
 - 财物是否仅限于动产？不限。
 - 财物是否包括违禁品？包括。包括国家专有的，包括任何人都不能拥有所有权的。
 - 财物是否包括葬祭品？包括。“葬祭品”不是指文物——有专门文物保护罪名体系，此时指的是比如随葬品。这种放弃所有权是附有条件的，这种附条件放弃所有权刑法依然要保护。
 - 财物是否包括人的身体？包括。当人体器官等和人体分离前，是人体健康的问题；分离之后，就具有人体属性。
 - 财物是否包括财产凭证？部分包括。将财产凭证限定在 具有价值、不记名、不挂失。比如购物券。
- …… 财物是否包括虚拟物？如游戏号

第二十八章 抢劫罪

一、概述

第二百六十三条 【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：

- （一）入户抢劫的；
- （二）在公共交通工具上抢劫的；
- （三）抢劫银行或者其他金融机构的；
- （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
- （五）抢劫致人重伤、死亡的；
- （六）冒充军警人员抢劫的；
- （七）持枪抢劫的；

（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

1. 概述：以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，强行夺取他人财物的行为

2. 司法解释

《关于审理抢劫案件具体适用法律若干问题的解释》

《关于抢劫过程中故意杀人案件如何定罪问题的批复》

《关于强迫借贷行为适用法律问题的批复》

二、构成

1. 主体：一般主体（14-16，包含形式责任能力人）

2. 行为：复行为犯（暴力、胁迫及其他手段的行为+强行夺取公私财物的行为）

（1）“暴力”：**无上限**，包含剥夺他人生命权（区别于强奸罪的“暴力”）；**有下限**，要能够足以抑制被害人反抗（**作为重罪，要严格解释**）。

（2）“胁迫”：只能是以**暴力为内容**的胁迫，不能是精神上的胁迫「**否则可能构成敲诈勒索等罪名**」。且该暴力具有**现时现实转化**的可能性。

（3）其他手段：**不能不知不敢反抗**的状态

（4）关于“手段”与“取财”的**因果关系**：暴力胁迫其他手段要与取财有因果关系，即被害人将财物留在当场是基于前面的暴力胁迫其他手段产生恐惧被迫而留下的。**比如行为人抢劫但是被害人基于同情给钱，此时不构成抢劫罪。**

（5）取财的表现形式：不重要。更重要的是因果关系。

3. 对象：人身及财物

4. 罪责：故意

三、转化抢劫问题

第二百六十九条【转化的抢劫罪】犯盗窃、诈骗、**抢夺罪**，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

关于三个适用条件的理解：

（一）“犯盗窃、诈骗、抢夺罪”的理解

1. 此时是罪行还是罪名？——是犯罪（既遂）or **故意+行为**？

不是罪名，而是罪行。不是要完全满足犯罪构成要件要素，只要有该罪的故意和行为即可。

2. 特殊的盗窃、诈骗、抢夺是否适用？——此时是特指“盗窃、诈骗、抢夺罪”还是整个“盗窃、诈骗、抢夺”罪名体系？

“特殊”的意思即有盗窃的行为但是不认定为盗窃罪，而是其他犯罪。此时是否可以转化？

Eg：盗伐林木罪等

首先，林木可以被评价为财物。其次，刑法没有评价其为盗窃罪，而是将其放在破坏生态环境资源的罪名中。

观点一（传统观点）：此处有一个“罪”字，所以就是特指这三种罪。

观点二（李翔）：

对比下列案例：

- 甲盗伐他人房前屋后自留地零星树木后被发现，适用暴力将被害人打成轻伤
- 乙盗伐成片林木后被发现，适用暴力将被害人打成轻伤

专门司法解释认为，“盗伐他人房前屋后自留地零星树木”为盗窃罪而不是盗伐林木罪。那么此处甲的行为就会被认定为抢劫，处以三到十年有期徒刑。

而此处乙“盗伐成片林木”构成盗伐林木罪（三年以下有期徒刑）而不是盗窃罪，后给其定为故意伤害罪为三年以下有期徒刑或拘役。此时法定最高刑只有六年。

此时就出现了非正义的结论，并不公平。说明传统解释思路有问题，必须重新寻找解释方法。

· 甲盗窃2000元后，被他人发现，使用暴力将被害人打成重伤。甲定抢劫罪，处10年以上有期徒刑。

· 乙原本打算盗窃，但是发现被害人后使用暴力并致被害人轻伤，取得2000元，出门后被他人发现，使用暴力，致被害人重伤。

乙：结论一：「**犯意转化，从新意**」抢劫罪+故意伤害罪（3-20年）；结论二：抢劫罪（269条）10年以上至死刑。

此时为了公平，对乙必须选择结论二，那么存在了抢劫转化抢劫的情况。

14-16周岁

最高法态度：不转化（不定罪或者定故意伤害罪、故意杀人罪）

最高检：转化（定抢劫罪）

· 分歧的原因：

最高法从刑事政策处罚必要性角度考虑，其认为本质还是盗窃诈骗抢夺，而对于14-16周岁这些罪名没有处罚必要性。但是如果重伤/死亡，则是侵犯人身权益，此时定故意伤害罪/故意杀人罪。

最高检从法律解释的位阶——刑法的体系性角度考虑，根据《刑法》第267条第2款“携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定（抢劫罪）定罪处罚”。若有15岁丙携带凶器抢夺c，被发现后使用凶器将c打成轻伤；若有15岁乙只是抢夺，被发现后从路边拿一个凶器将被害人达成轻伤。（第269条中的“抢夺”没有限定带不带凶器）而此时按照最高法，乙就是不定罪，而丙要定抢劫罪，这是第一步不公平。进一步，“携带凶器抢夺”应该构成抢劫罪，但是如果携带凶器抢夺被发现后使用凶器打人按照最高法又不定罪了，无疑是在鼓励携带凶器抢夺人最好让人发现一下再打人就能不定罪了，这是第二步不公平。

实务中由于法院有后位优势，所以以法院为主要观点。

（二）当场使用暴力或者以暴力相威胁

- 现场、抓捕过程
- 程度要求
- 对象（不一定是失主，也不要求对方认识到行为人的先前行为）
- 排除对自身使用暴力或者体现威胁

例：甲盗窃后被他人发现，甲以加害自己威胁他人不要对其实施抓捕

（三）窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭证据

三者**必须兼备**

四、抢劫罪的加重情节研究

1. 入户抢劫的理解——标准：**要与家庭生活密切相关，与外界相对隔离**

如：牧民的帐篷、渔民的船只、租房都可以被认定为“户”

(1) 【讨论】商铺中前面经营，后面住人；在白天作为经营场所，晚上作为生活场所，算“户”吗？

前面抢劫的不是，后面抢劫的是；抢劫白天抢劫就不是，晚上抢劫就是。

(2) 相对隔离不考虑合法或者非法，只认定实然状态——**违章搭建不影响“户”的认定**

(3) 入户：具有**非法性**即可，不一定要具有抢劫等目的。因为这样法律上可以不将非法侵入住宅罪和抢劫罪进行数罪并罚（“住宅”和“户”实质相同），就将入户非法性作为抢劫的法定刑升格条件。

2. 在公共交通工具上抢劫的认定——**以公共交通工具的私行人员作为抢劫对象（对象加重，而非地点加重）**

(1) 由此排除小型公共交通工具。如出租车

(2) 由此可以解决 **拦公共交通工具然让乘客下来抢劫**

3. 抢劫银行和金融机构的认定——**以银行或者金融机构的资金作为抢劫对象（对象加重，而非地点加重）**

4. 多次抢劫或者抢劫数额巨大的

5. 抢劫致人重伤死亡的

6. 冒充军警人员抢劫的理解

(1) 若就是军人或者警察，那么是从重情节，不是加重情节。

(2) “冒充”：行为人会以某种方式向被害人显示身份

7. 持枪抢劫的理解

(1) “持”即可，不用使用

(2) 同样，在法律上不和非法持枪数罪并罚，直接将持枪作为抢劫罪的法定刑升格条件。

8. 抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资

第二十九章 盗窃罪

一、概述

第二百六十四【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

1. 概述：以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大或多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃行为。

2. 司法解释

《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体适用法律若干问题的解释》

《关于审理破坏森林资源刑事案件具体适用法律若干问题的解释》

《关于审理未成年人刑事案件具体适用法律若干问题的解释》

《关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》

二、构成

1. 行为：秘密窃取数额较大、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃

2. 对象：公私财物（财物所有权或占有）

3. 罪责：故意（不存在过失）

三、注意事项

1. 非法占有（不法所有）目的：非法占有目的由“（对所有人或占有人）排除意思”与“（对财物）利用意思”构成。前者重视的是法的侧面，后者重视的是经济的侧面，二者的机能不同。

其中利用意思方面：

（1）利用意思不限于遵从财物原先设定的用途加以利用

* 包括满足行为人特定的心理需求

（2）不能认为行为人具有归还的意思就排除行为人非法占有目的

即，非法占有目的不一定是永久的非法占有目的。

员工为了向老板索要工资，将老板的车秘密开走，说“你什么时候发工资，什么时候我把车还你”。——构成盗窃。

“我把你的xx物拿走，等xx时间还给你”——为了避免这种情况出现，应当认定构成犯罪。

2. 占有问题

核心：主客观相统一，更侧重事实占有。

刑法上占有重在事实上的支配，占有意思对事实的支配的认定起补充作用。只要求他人对其事实上支配的财物具有概括的、抽象的支配意识，既包括明确的支配意思，也包括潜在的支配意识。具体分述如下：

(1) 只要是在他人的事实支配领域内的财物，即使他人没有现实地握有或监视，也属于他人占有。

高中同学乙到甲家里来玩，为了表示对甲在高中帮助的感谢，乙带了一万来，并在甲不知情的情况下塞到了沙发底下。过几天丙来甲家，偶然发现并拿走了一万元。考虑到甲家为甲事实支配的领域，即使甲没有现实地握有或监视，也构成甲的占有。丙即为盗窃。

典型·出租车遗留财物 须视为出租车司机占有，不能视为遗失物

(2) 虽然表面上处于他人支配领域之外，但存在可以推知由他人事实上支配的状态时，也属于他人占有的财物。

校园骑自己自行车到教学楼下，没上锁，他人将自行车拖走。存在可以推知由他人事实上占有。

小情侣去公园赏樱花，把汽车没锁放在路边，他人将汽车开走并说“今天在路边捡到了一辆汽车”。

【保洁捡到一百多万黄金】甲登机排长队，队伍旁边有一个垃圾桶。甲拎着黄金包就随手放在垃圾桶旁边且没有走一步放一步。保洁人员即将包拎走，后来才发现黄金。不能认为所有人和包有距离了，就失去了占有。一般观念中可推知，财物由行为人所占有。

(3) 在特定场所，所有人、占有人在场的，原则上应认定为所有人、占有人占有。

下课去洗手间，将手机留在座位上。认为手机仍然由所有人占有，即使没有现时随身携带。

【二万六到底谁占有】被害人到银行存钱二万六千，夫妻也去银行办业务。被害人单子填好后，钱放在桌子上。后来想起来时钱就没有了。过程中原来是，一老太太看到了全程，顺手就将钱装在口袋里，后携老伴快速离开。

(4) 主人饲养的具有回到原处能力或习性的宠物，不管宠物处于何处，都应认定为饲主占有。

(5) 即使原占有者丧失了占有，但当该财物转移为建筑物的管理者或者第三者占有时，也应认定为他人占有的财物。

典型·遗留于酒店的东西被后住者拿走 管理者属于事实上的支配，因为酒店的房间具有排他性，即要么是后来住户要么就是酒店工作人员。所以后来者将前面的人的财物拿走，属于盗窃。

【区别】侵占：事实上的支配—排他性

华政教学楼里面忘了带走自己的包。此时华政教学楼的教室属于开放性的，随意出入的。此时财物需要评价为无人占有/原所有人失去占有，此时拿走财物的人只能评价为侵占。

(6) 存款占有归属，存款人占有债权。

(7) 数人共同管理某财物，而且存在上下主从关系时，下位者不占有该财物。此时下位者容易构成盗窃。

保姆偷走主人的东西。仍然认为该财物由主人占有。

销售将店里的衣服直接拿走。仍然认为该财物由店老板所有，所以构成盗窃而不是侵占。

出车站时有人帮忙拿行李拿到车上。只是辅助者，并不占有该财物。

(8) 行为人受他人委托占有某种封缄的包装物时，封缄物整体由受托人占有，但内容物为委托人占有。受托人不法取得封缄物整体的，成立侵占罪；取出其中的内容物的，成立盗窃罪。

(9) 死者的占有主要由三种情况：一是行为人以抢劫故意杀害他人后，当场取得他人财物（抢劫罪）；二是行为人出于其他目的地杀害他人后，产生非法占有他人财物的意思，取得死者的财物；三是无关的第三者从死者身上取得财物。后两种行为认定为侵占罪。

所有权说：故意杀人罪+盗窃罪（遗产继承人所有）

占有说：故意杀人罪+侵占罪（遗产继承人所有，但并不占有。所以此时的财物属于无人占有的状态）

四、盗窃罪中需要深入研究的问题

1. 秘密性不是其必要构成要件要素（学说）。

原来：（通说）相对（财产占有有人和所有人/财产管理人）的秘密性

（财产占有有人和所有人）只有所有人没有看见，其他人在公交车上都看见了/监控排的清清楚楚小偷的扒窃。此时仍然认为构成盗窃罪。

此时强调秘密性是必要构成要件要素，公然的视为抢夺。

现学说：秘密性不是其必要构成要件要素——重新划分了盗窃罪和抢夺罪之间的界限。

将抢夺罪对象范围限缩，只有行为人对物使用暴力造成人身伤害可能性时才构成抢夺。（其他评价为公然盗窃）如公然抢女生身上的项链。（抢劫：必须对人身有暴力行为）

2. 盗窃公私财物，数额较大：

我国刑法立法是定性+定量。【比较法】美国是立法定性，司法定量。

【延伸】故意中的认识因素包不包含对于罪量的认识：（李翔）对于罪量有认识可能性 否则排除故意。*注为“可能性”，不是确定的数额认识。

此时会产生的结果：受教育程度越高，注意义务越高，（李翔）这才是公平的。

| 则在盗窃罪中，行为人必须对犯罪数额具有认识可能性。

【农名工到北京培训基地随便摘了两串葡萄价值12万6千块】此时行为具有盗窃性质，但是缺乏对于财物价值的认识，所以出罪。

3. 价值：

数额要求或者使用价值要求（身份证等）

价值要求：考虑使用价值及对特定人的价值。

4. 窃取行为是排除他人对财物的支配，建立新的支配关系的过程。窃取的手段与方法没有限制，即便使用了欺骗方法，但如果该欺骗行为并没有使对方基于认识错误处分财产的，仍然成立盗窃罪

5. 多次盗窃，是指二年内三次以上盗窃。

A. “次”应根据客观行为认定，时间、地点、被害人要素

B. 不以每次成立盗窃行为既遂为前提，也不要求每次盗窃行为均成立盗窃罪（更加注重行为人的主观恶性，没有入罪要求）

6. 入户盗窃。合法入户后盗窃的，不宜认定；非法入户，即使入户后才产生盗窃犯意的，也应认定为盗窃罪。

强调入户非法性，没有入罪要求，因为行为上侵害了另外的法益。

5. 携带凶器盗窃的。注意与第267条第2款区别。解释方法论上的问题。

组织未成年人乞讨/违反治安管理活动罪设定入罪门槛时，非常精细。前者因为考虑到乞讨行为本身不具有非法性，所以需要“暴力、胁迫等”要求；后者本身就有非法性，所以没有入罪要求。

没有数额的入罪要求，要找其他的入罪要素，即“携带凶器”。

6. 扒窃要素：公共场所；他人随身携带的财物；值得刑法保护。

行为入主观恶性会更大。

五、盗窃罪的认定

1. 盗窃罪与盗窃枪支、弹药、爆炸物罪

2. 盗窃罪与信用卡诈骗罪

【讨论】为什么盗窃信用卡并使用认定为盗窃罪而不认定为信用卡诈骗罪？

法律拟制，不能推广到抢劫、诈骗、抢夺等其他犯罪。

3. 盗窃罪既遂、未遂的认定标准——行为人取得（占有）了财物（行为人的占有与占有人的失去占有一般是并行的），且达到一定数额

结合具体案件本身进行综合评价：

柜台用调包方式偷戒指，但是未出商场被逮住。戒指本身形态容易控制，理解为离开柜台盗窃既遂。

偷电瓶车过程中被发现，被追赶。此处不宜评价为盗窃既遂。

六、盗窃罪的死刑废除

1997年刑法

- 盗窃金融机构，数额特别巨大。
- 盗窃珍贵文物，情节特别严重。

刑法修正案八：

- 废除盗窃罪死刑。

第三十章 诈骗罪

第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

一、概述

1. 概述：以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为

2. 司法解释：

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

《关于审付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》

《关于对伪造学生证及贩卖、使用伪造学生证的行为如何处理问题的批复》

《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》

二、构成

1. 罪责：故意（非法占有目的）

2. 对象：他人财物

3. 行为：虚构事实或隐瞒真相

三、基本问题

1. 诈骗罪的基本构成模式【行为要素】

Step 1 行为人实施欺骗行为（虚构事实或隐瞒真相）

Step 2 对方产生或者继续维持认识错误

Step 3 对方基于认识错误处分（或交付）财产

Step 4 行为人获得或者使第三者获得财产

Step 5 被害人遭受财产损失

2. 欺骗行为

（1）受骗人对行为人所诈称的事项有所怀疑仍然处分财产的，也不影响诈骗罪的成立

（2）在欺骗行为与受骗者处分财产之间，必须介入受骗者的错误认识（因果关系环环相扣）；如果受骗人不是因欺骗行为产生错误认识而处分财产，行为人的行为就不成立诈骗罪（但有成立诈骗未遂的可能性）

【涉及·区别】敲诈勒索：基于恐惧害怕交付还是基于错误认识

（3）欺骗行为的受骗者必须具有处分财产的权限或者处于可以处分财产地位的人，但是不必是财物的所有人或占有人。受骗者还必须具有处分财产的意识。

小朋友被骗说“将妈妈家里的电视机拿来给糖吃”——盗窃罪的间接正犯，因为不具有处分财产的权限也不具有处分财产的意识。

（4）被骗者不限于特定的人

3. 处分财产

(1) 处分财产不限于民法意义上的处分财产（即不限于所有权权能之一的处分），而意味着将被害人的财产转移为行为人占有，或者说使行为人或第三人取得被害人的财产。

· 包括在占有基础上的处分；（“不占有”）委托基础上的处分（保姆拿着主人的东西）【三角诈骗】。

(2) 受骗者处分财产必须有处分权限。

(3) ☆☆☆受骗者处分财产时必须有处分意识。即认识到自己将某种财产转移给行为人或者第三人占有，但不要去对财产的数量、价格等具有完全的认识。

学者：处分意识可以不要说。考虑到目前电信诈骗的频发，其中被诈骗人有时并没有处分意识。

【案例对比】

(1) 甲在超市购物时，将便宜的照相机价格条形码与贵重照相机条形码予以更换，使店员将贵重照相机以便宜照相机的价格“出售给甲”。店员能够意识到自己在处分照相机，只是对价格有错误认识。甲涉嫌诈骗。

(2) 乙将一个照相机包装盒里的泡沫取出，使一个包装盒里装入两个照相机，然后拿着装有两个照相机的一个包装盒付款，店员只收取一个照相机的货款。店员能够意识到自己在处分照相机，只是对数量有错误认识。乙涉嫌诈骗。

(3) 丙在超市购物时，偷偷将一箱方便面取出几袋，并将一个照相机放在方便面箱子里，然后拿方便面箱子付款，店员收取了一箱方便面的货款。店员没有处分照相机的意识，不能认为被害人在处分财产，进而不能认为丙构成诈骗，只能构成盗窃。* 注意：此处也有“虚构事实”。所以对于诈骗和盗窃罪而言，即使虚构事实，则不当然地构成诈骗。核心区别在于处分意识。

(4) 丁发现被害人一本名为《考研宝典》的书里面夹有一张“祖国江山一片红”邮票一张，便讨要该书，被害人将该书送给丁，丁将邮票据为己有。被害人并不具有处分邮票的意识，不能认为在处分财产，进而不能认为丁构成诈骗罪，亦不构成盗窃罪，涉嫌侵占罪。

4. 获得财产

(1) 积极财产的增加

(2) 消极财产的减少 eg: 免除债务

5. 财产损失

(1) 在诈骗不法原因给付物的情况下的处理

【法秩序统一原理】刑法具有保障法的地位，保障其他法律运行，而每个部门法都有相应调整范围。各部门法有一个共同的任务“保证法秩序的统一”。

在民法中，对于不法原因给付，行为人没有办法对于所获的不法财产有所保护。所以有一种观点认为，基于法秩序统一原理，民法都不保护，刑法也不应当保护；另一种观点认为，刑法要保护占有，保护的範圍要比刑法更加宽泛，所以此处不讨论时合法占有还是非法占有（用以解决“黑吃黑”）。

(2) 通过欺骗方式使他人免除非法债务的，不存在财产损失。骗卖淫者免除个人债务不构成诈骗罪；给过卖淫者钱再骗回来，并不构成诈骗罪。

(3) 以欺骗方法取得对方不法占有的自己的所有的财物的，不成立诈骗罪。（本权者恢复权利的行为）

(4) 行为人虽然提供了价格相当的商品，但在告知了事实真相后对方将不付金钱的场合，故意就商品的效能等作虚假陈述，使对方将不付金钱的场合（有所“让利”），故意就商品的

效能等作虚假陈述，使对方误信商品的效能，而接受对方交付的金钱的，**构成**诈骗罪。「作出对方不需要的让利」

(5) 行为人实施欺骗行为，导致受骗者就所交付财产的用途、财产的接受者存在法益关系的认识错误时，即使受骗者没有期待相当给付，也应认为存在财产损失（对财产接受者有期待），行为人的行为成立诈骗罪。诈捐「没有期待相当给付，但是对于财产接受者有期待」

四、特殊类型的诈骗罪研究

- 三角诈骗——财产处分人与被害人不同一的情况
- 诉讼欺诈的行为如何定性
- 赌博诈骗——伪装输赢的偶然性（原本没有，现认为须加入具体区分：赌博中核心在于成本性+射幸性，如果根本没有赢的可能，就是诈骗）——对最高人民法院1995.11.6司法解释的质疑：当时按照赌博罪处理，现在看不合适还是按照诈骗处理。
- 无钱饮食、住宿——不能认定为诈骗罪
- 二重买卖——诈骗罪或者侵占罪（所有权转移但约定由出卖人暂时占有一段时间，行为人再卖）

五、诈骗罪的认定

- 诈骗罪与其他特殊诈骗罪的关系

266条“本法另有其他规定的，依照其他规定”，由此诈骗罪属于一般犯罪，此外还有金融诈骗、合同诈骗、使用假币、侵犯著作权。

- 诈骗罪与盗窃罪的界限：被害人基于错误认识处分财产
- 向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为——**机器不能被骗**。认定为盗窃，不是诈骗。
- 从没有处分能力的幼儿、精神病患者那里取财——不能认定为诈骗罪，缺乏处分意识、权限、能力等
- 【讨论】以借打手机为名进而非法占有他人手机

【指导案例27号：臧进泉等盗窃、诈骗案】

裁判要点：行为人利用信息网络，诱骗他人点击虚假链接而实际通过预先植入的计算机程序窃取财物构成犯罪的，以盗窃罪定罪处罚；虚构可供交易的商品或者服务，欺骗他人点击付款链接而骗取财物构成犯罪的，以诈骗罪定罪处罚。相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条

核心：被害人有没有认识到自己实际在处分财产。行为人只有处分1元的意识没有处分几十万的意识。

裁判理由：盗窃是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为；诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。对既采取秘密窃取手段又采取欺骗手段非法占有财物行为的定性，应从行为人采取主要手段和被害人有无处分财物意识方面区分盗窃与诈骗如果行为人获取财物时起决定性作用的手段是秘密窃取诈骗行为只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有“自愿”交付财物的，就应当认定为盗窃；如果行为人获取财物时起决定性作用的手段是诈骗，被害人基于错误认识而“自愿”交付财物，盗窃行为只是辅助手段的，就应当认定为诈骗。

第三十一章 抢夺罪

一、概述

1. 概述：指以非法占有为目的，公然夺取公司财物，数额较大或者多次抢夺的行为

2. 司法解释

《关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于审理抢劫案件具体适用法律若干问题的解释》

二、构成

1. 行为：公然强行将他人控制下的财物夺取据为己有，数额较大或多次抢夺

(1) 公然：具有相对性。

2. 对象：公司财务（不包括特定物品）

3. 罪责：故意

三、抢夺罪的认定问题

· 暴力的指向——物

不能限定在“夺”的要素上，进而不能觉得被害人具有紧密占有关系。而应该强调被害人对于财物有占有意识即可。被害人与财物具有紧密占有关系是一种抢夺，不是全部。

【区别】抢夺罪&抢劫罪。前者是针对物的有形力，后者是针对人。

· 利用机动车辆抢劫的认定 飞车抢夺

（李翔）创设性司法解释不具有约束力，不然立法干嘛

最高院当时针对广东飞车抢夺的司法解释具有创设性

· 携带凶器抢夺的认定（转化为抢劫罪）

· 上述凶器的认定：（1）在性质上就可以被评价为凶器 管制刀具（2）在用法上可以被评价为凶器 板砖（性质属于建筑材料）

· 上述携带的认定：行为人为抢夺时候使用而携带，或者在抢夺时意识到自己携带（不是客观状态）。而不是仅仅认定为“携带”的客观状态。

四、几种需要反思的表述

· “抢夺的乘人不备”问题：是一种表现形式，不是唯一表现形式

· “抢夺的公然性”的问题：是相对的，不要求第三人在场。

· 抢夺罪与抢劫罪关系问题，其中“成立抢夺罪，只能是对物的暴力行为，不能包涵对人的暴力行为”的问题：不能单纯认为只要对人暴力就是抢劫，因为抢劫的暴力有程度性要求。

· 关于“携带凶器盗窃”转化为“携带凶器抢夺”问题：前者为盗窃罪，后者转化为抢劫罪

· 甲使乙手持凶器与自己同行，甲实施抢夺A财物，如何处理？（见携带的认定）

第三十二章 侵占罪

一、概述

1. 概述：指以非法占有为目的，将代为保管的数额较大的他人财物占为己有，拒不退还或者将他人的遗忘物、埋藏物占为己有，数额较大，拒不交出的行为

二、构成

1. 行为：已然持有（合法持有）+非法占有

【区别】和盗窃罪最大的区别：财物处于行为人的占有

2. 对象：代为保管的他人之物，埋藏物、遗忘物

3. 罪责：故意

三、侵占罪的基本问题

1. 【普通侵占】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，或者【遗忘物/埋藏物侵占——侵占脱离占有物】将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的行为。包括普通侵占和侵占脱离占有物。

（1）普通侵占一般发生在熟人之间，所以设置为“告诉才处理”

（2）侵占脱离占有物

· 【区别】遗失物 vs 遗忘物——一般以财物所有人的记忆力作为判断标准。

遗失物无法想起；遗忘物可以想起。

区分目的：限制处罚范围。遗失物不考虑刑法处罚。

· （李翔）有无必要对遗忘物和遗失物进行区别？

不论是否存在委托关系，只要非行为人所有，就要受到刑法处罚：

宽泛遗忘物定义：非经他人本意而失去控制，偶然（即不是基于委托关系）由行为人占有或者占有人不明的财物。

底层逻辑：君子社会。刑法理论根据：评价行为人行为应当从行为人角度分析，不能从被害人角度分析记忆力——行为人是否会定罪，完全取决于被害人记忆力的好坏。

· 埋藏物：埋藏于地下，所有人不明或应由国家所有的财物。

（3）“拒不退还，拒不交出”：说明要求权利人至少有一次权利的主张过程。限制了处罚范围

“非法占为己有”与“拒不退还”的关系：后者是对前者的强调或者补充说明，即将自己占有的他人财物变为自己所有的财物。

【例外】如果行为人将财产处分——遵从财物的用法，例如出卖、赠予、消费、抵偿债务等，就表明其“非法占为己有”。如果单纯毁坏则不能成立本罪。| 即如果代为保管的财物不可替代，而作为保管人以所有人自居消费使用。此时可以认定为：明知道消费后财物灭失，直接认定为“非法占为己有”。

· “拒”的理解：不可将行政权直接用司法权替代。

2. 代为保管——事实上的支配和法律上的支配，以财物所有人与行为人之间存在委托关系为前提

3. 基于不法原因而委托给付的财物，能否成为本罪的对象。

4. 窝藏或者代为销售的赃物能否成为侵占罪的对象

5. 侵占行为的理解——取得行为

四、侵占罪疑难问题探讨

1. 侵占罪与盗窃罪的区别——判断财物由谁占有，是否脱离占有

2. 行为人认识错误

例如，行为人将他人占有的财物误认为他人的遗忘物而非法占为己有；本来是遗忘物，行为人以为是他人占有的财物而非法占为己有

3. 由于侵占罪的对象难以排除国家、集体所有的财产，立法上的亲告罪设置似有疑问：**告诉才处理包括控告与起诉。**

华东政法大学 法律学院 240101021016

第三十三章 职务侵占罪

一、概述

1. 概述：指公司、企业或者其他单位的人员；利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大的行为。

2. 司法解释

《关于村民小组组长利用职务便利非法占有公共财物行为如何定性问题的批复》

《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》

《关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何认定问题的批复》

《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》

二、构成

1. 主体：公司、企业或专业其他单位的工作人员

2. 利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有

(1) 职务上的便利：主管、管理、经手

——职权来自于单位授权，不是公权力。

采购的选择权

(2) 职务侵占罪和侵占罪无关，职务侵占只是通过职务便利转移占有状况，不是先基于职务行为占有再变所有。

【快递小哥倒卖快递涉案8万元】定侵占还是职务侵占？

按照侵占，8万已经涉及“数额较大”；按照职务侵占，6万才入罪。

3. 对象：本单位的财物（法益：职务行为廉洁性）

4. 罪责：故意+非法占有目的

第三十四章 敲诈勒索罪

第二百七十四条 敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

一、概述

1. 概述：指以非法占有为目的，采用威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的行为

2. 司法解释☆☆☆

《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》

《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》

二、构成

1. 行为：采取威胁、要挟方法强行索取公私财物

(1) 【区别】诈骗罪 VS 敲诈勒索罪——是否精神上受到强制

前者是基于认识错误，后者是受到威胁强迫

(2) 结构

行为人以不法所有为目的对他人实施威胁——对方产生恐惧心理——对方基于恐惧心理做出处分财产的决定——行为人取得财产

·被害人的过错不能够阻却行为人的违法性。

【知假买假】从行为人占有非法占有目的使对方的角度，和受害人是否有过错无关。

【例外】行为人基于权利被侵害而维权不能定敲诈勒索。

·虚构事实——看被害人什么状态下做出处分

基于虚构事实产生错误认识——诈骗

基于虚构事实产生恐惧心理——敲诈勒索

兼备——想象竞合

甲饭馆吃饭，随身携带苍蝇。吃完以后，把苍蝇放进去，叫来老板说不给钱就公开。

——兼备，想象竞合。

·单位不能构成敲诈勒索，对于单位中实施敲诈勒索的人，可以构成敲诈勒索。

2. 对象：公私财物

3. 罪责：故意+非法占有目的

三、敲诈勒索罪的疑难问题

1. 与抢劫罪的区别（共性：都涉及暴力胁迫）

(1) 抢劫中的暴力强调最低程度的要求：必须要足以抑制被害人的反抗；敲诈勒索中的暴力没有程度性的要求，但也强调暴力对被害人心理上的压制。

(2) 抢劫罪中的暴力实现时间具有当场性（当场转化为现实的可能性），对于财产的要求必须要与暴力之间存在因果关系；若为事后的一段时间，则只能评价为敲诈勒索。

2. 与绑架罪的界限（共性：被迫交付财物）

(1) 绑架是向第三人发出财产要求，是利用第三人对于被绑架人人身、财产的忧虑。

(2) 绑架有一个暴力实现的当场性，因为起刑点很高，所以暴力程度要求更高。绑架中对于被害人的人身控制一定包含一个行为：**非法拘禁（实质上要是客观真实的）**。

【研讨】甲乙合谋后，由与丙相识的甲将丙骗往外地游玩，乙给丙的家属打电话，声称已经“绑架”了丙，借以要求“赎金”的行为，如何认定？敲诈勒索罪。绑架要有实质上的非法拘禁，所以此处为敲诈勒索。被害人为丙的家属，因为丙的法益没有任何侵犯。

3. 既遂、未遂的判断标准——**行为人是否获得财物**

华东政法大学 法律学院 240101021016

第三十五章 故意毁坏财物

第二百七十五条 故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。

一、概述

1. 概述：故意非法毁灭或者毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的行为
2. 司法解释

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》

二、构成

1. 行为：非法毁坏财物

(1) 毁坏的理解（实体破坏说到功能妨碍说的转变）：

有损财物效用的一切行为。不限于从物理上变更或者消灭财物的形体，而是包括丧失或者减少财物效用的一切行为。

放走笼中的小鸟；消除录影带中的影像；在别人字画上题字；将他人戒指沉入大海；恶意炒股；销售人员恶意降价销售本公司产品；销售人员辱骂多家与本公司关联客户「争议」；在别人汽车上的喷漆行为。

2. 对象：公私财物
3. 责任要素：故意

第三十六章 拒不支付劳动报酬罪

第二百七十六条 以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。

司法解释：

《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》

华东政法大学 法律学院 240101021016

第四讲 危害公共安全类犯罪

第一百一十四条——第一百三十九条

· 兜底性：第114、115条对于行为方式的兜底，不是一个章节的兜底。

【景德镇一家三口被撞身亡案】——危险方法危害公共安全or交通肇事罪

第三十七章 危害公共安全罪

一、概述

1. 概述：故意或者过失实施危害不特定或者多数人的生命、健康或者重大公共财产安全的行为

二、构成

1. 行为：实施危及公共安全，已经造成严重后果，或者足以造成严重后果的行为。可以是作为也可以是不作为（法益：生命健康法益或者财产法益）

→ 不要求出现实害结果，但是需要达到一定程度。

2. 对象：公共安全——不特定或者多数人的生命、健康和重大公共财产安全。

（1）是指犯罪行为危害的对象，不是指特定某几个人或者特定财产。

甲针对仇人乙，给其家里埋炸弹。危害了多数人，即乙的一家。但是此时可以从空间上认识到是乙的一家，依旧是特定人，不构成危害公共安全罪。

（2）不是特定对象就一定不构成危害公共安全吗？——不是。如甲在乙的车子下面埋炸弹，但是乙的车辆每天都要经过陆家嘴。

2. 主体：多数是一般主体，但也有少数是特殊主体（如危害铁路安全中，必须是相关工作人员）。

3. 责任要素：可以是故意，也可以是过失

→ “过失”：

第一百一十五条第2款 过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。（针对的是第115条第1款，不针对第114条，因为所有的过失犯都有实害结果）

三、种类

1. 适用危险方法危害公共安全的犯罪

2. 破坏公共设施、设施危害公共安全的犯罪

3. 实施恐怖活动危害公共安全的犯罪

4. 违反枪支、弹药、爆炸物及核材料管理的犯罪

5. 重大责任事故的犯罪

四、基本问题

1. 一般法条和特殊法条竞合

危害公共安全罪一般会出现侵害生命健康和财产的结果，所以和故意杀人、故意伤害、故意毁坏财物等罪名构成法条竞合。其中危害公共安全类除了侵害这一类法益又侵害了公共安全，相当于多加一个限定，所以属于特殊法益。所以此处是运用“特别法优于一般法”的处理方法。

2. 客观的处罚条件：客观要素达成了，不论主观要素直接构成犯罪

如此处的佩戴枪支

3. 第114条于第115条第1款关系

第一百一十四条 放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪之一，是指放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

第一百一十五条第1款 放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪之二，是指放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

(1) 具体危险犯与实害犯

(2) 未遂犯与既遂犯

处罚提前：将未遂单独立法

(3) 基本犯与结果加重犯罪

结果加重情节不考虑结果是否可归罪于行为人，即不考虑行为人的主观要素。

第三十八章 放火罪

一、概述

概述：是指故意放火焚烧建筑物、森林等物体，危害公共安全的行为

二、构成

1. 对象：公共安全，即**不特定多数人**的生命、健康或者重大财产的安全
2. 行为：放火
→ 需达到危害公共安全的程度：一般可以延烧到周围区域
点燃了高速旁边的桔梗 不属于对公共安全造成危害。
3. 主体：一般主体，14周岁以上的自然人
4. 责任要素：故意才能构成本罪，包括直接（**希望**）和间接（**放任**）故意。

三、基本问题

1. 既遂与未完成形态

通说观点：“独立燃烧”

问题：构成既遂的时间点很早，那么就限缩了犯罪中止的成立范围，妨碍了行为人作出灭火措施。

解释：刑法就是为了惩罚犯罪行为本身，应当对这种危险的行为进行处理。

其他观点：“造成严重后果”

问题：刑法将放火等规定为具体危险犯，采取这种观点背离了罪刑法定。

【莫焕晶案】被告人主张其对于四人死亡的结果排斥，属于过于自信的过失，不是故意，不够成放火罪。

step1 从基本犯与结果加重犯罪的角度：其并非对于放火行为有过失，而是至多是对死亡结果有过失。而死亡结果作为结果加重并不考虑行为人的主观要素。

step2 区分间接故意与过于自信：虽然在认识程度上很接近，但是在手法的动机时不同——预见概率低于间接故意。

【自制燃烧瓶投掷向强拆的城管大队】构成放火罪or妨害公务罪？

(1) 构成妨害公务，但是放火罪不能单独成立，因为不是不特定多数人（无波及）。

(2) 牵连关系：如果是牵连关系：需社会观念上，两者一般以手段和结果连带出现。此时用自制瓶放火，不是社会意义上的一般观念。

第三十九章 爆炸罪

一、概述

故意用爆炸方法危害公共安全的行为。

二、构成

1. 对象：公共安全，即不特定多数人的生命、健康或者重大财产的安全
2. 行为：以爆炸的方法危害公共安全的行为，可以作为可以不作为。
→ 不需要行为人对实害结果有具体认识（结果加重犯）
3. 主体：一般主体，即14周岁以上的自然人
4. 责任要素：故意，包括直接故意和间接故意。

三、认定

1. 本罪与破坏电力设备罪、破坏易燃易爆设备罪和破坏广播电视设施、公用电信设施罪（设施类）的界限
设施类进一步对于犯罪的对象进行了限制，所以这一类犯罪在公共安全犯罪中又是更加特殊的犯罪，所以按照“特别法优先于一般法”的原则，应该成立后者（设施类犯罪）。
2. 本罪与故意毁坏财物罪的界限
故意毁坏财物罪属于一般犯罪，爆炸罪属于特定犯罪。
3. 本罪与危险物品肇事罪的界限
后者属于责任事故类犯罪。
二者主观要素不同：肇事可能属于过失类犯罪。
一般过失违反（老百姓生活准则），属于爆炸罪；业务过失违反，够层危险物品肇事罪。
4. 本罪的共犯与间接正犯
人形炸弹——间接正犯

第四十章 投放危险物质罪

一、概述

投放危险物质，危害公共安全。

二、构成

1. 行为：投放危险物质

(1) 方式：

- ① 将危险物质投放于供不特定或者多数人饮食的食品或者饮料中
- ② 将危险物质投放于供人、畜等使用的河流、池塘、水井等中。
- ③ 释放危险物质，如将沙林、传染病病原体释放与一定场所。

(2) 性质：

- ① 投放危险物质的行为必须危害公共安全，因此，故意使用危险物质杀害特定个人或特定牲畜的，不构成投放危险物质罪，而成立故意杀人罪、盗窃罪或者故意毁坏财物罪。

案例1 张三欠李四一笔钱不想还，于是拿了一只自条鸡，涂上毒强，挂在李四家门口。李四打开门一看，居然把鸡直接扔了。张三又把鸡捡了起来，扔在李四家米缸。当天晚上李四一家三口喝稀饭，全都中毒而死。

属于特定，构成故意杀人罪。

案例2 陈某与陆某因琐事多次发生口角，陈某怀恨在心，决意报复。某日晚陈某找来一支一次性注射器，抽取半针筒农药，潜行至陆某门前丝瓜棚处，将农药注入瓜藤上所结的多条丝瓜中。次日晚，陆某及其外孙女食用丝瓜后，出现上叶下泻等中毒症状，后陆某被抢救存活，而陆某外孙女抢救无效死亡。

丝瓜藤在路边，可能不特定多数人，可以构成投放危险物质罪。

- ② 投放虚假危险物质，扰乱社会秩序的，不成立投放危险物质罪，而成立其他犯罪(投放虚假危险物质罪)。
- ③ 故意传播突发性传染病病原体，危害公共安全的，成立以危险方法危害公共安全罪。

2. 责任要素

案例 徐某长期开店从事预包装、散装食品销售，某日上午徐某在店内准备用亚硝酸盐调配硝卤水，因为一时慌乱将亚硝酸盐遗留在经营区域内。店内其他销售人员误将亚硝酸盐当作白糖混入白糖销售箱里面，将亚硝酸盐当作白糖销售给张某，蔡某等人。当天下午被害人唐某在食用张某购买的白糖后发生亚硝酸盐中毒死亡，九天后被害人蔡某食用购买的白糖后也发生亚硝酸盐中毒造成轻微伤。

本案是否有人该负刑责?如果有，该负何种责任?

- (1) 对于销售人员，不要求其对于亚硝酸盐有认识要素，所以没有刑事责任。
- (2) 二者不能构成共同犯罪，因为没有共同故意。
- (3) 对于徐某：

销售人员的介入并不异常，不能够阻断因果关系。

“投毒”要有“投”的行为，但是此处徐某没有投放行为，所以仅仅构成过失。

第四十一章 以危险方法危害公共安全罪

第一百一十四条 【放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪之一】放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处3年以上10年以下有期徒刑。

第一百一十五条 【放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪之二】放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

一、概述

是指以防火、决水、爆炸、投放危险物质之外的危险方法危害公共安全的行为。

二、构成

1. 对象：公共安全，即不特定多数人的生命、健康或者重大财产的安全
2. 行为：行为人以防火、决水、爆炸、投放危险物质**相当的方法**危害公共安全。如驾车撞人、设电网、将载客的车开下悬崖、用机枪向人群扫射等。可由作为或者不作为构成。

(1) **偷掉井盖** 是否构成此罪存在争议——类似高空抛物范围较小

(2) “相当的方法”：

将自己的身上涂满汽油 理论上没有“延烧”，没有和防火罪相当。但是司法实践中考虑到对周围群众造成了恐慌，所以仍认定为以危险方法危害公共安全罪。

(3) **高空抛物** 是否构成此罪存在争议——在高空抛物罪之前，司法实践中认为构成以危险方法危害公共安全罪。

学者认为：高空抛物范围较小，最终基本只能打伤特定一个人。就像概括的故意和择一的故意的区分。高空抛物和防火等危害公共安全行为最大的区别就在于后者是不特定不知道数量的人，但是前者是择一的。

3. 主体：已满16周岁

注：14-16周岁怎么办：按照八大最行中的故意杀人和伤害行为定。

4. 责任要素：故意才能构成此罪，包括直接或者间接故意。

第四十二章 破坏交通工具罪

一、概述

破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生颠覆、毁坏危险，尚未造成严重后果或者已经造成严重后果的行为。

二、构成

1. 对象：只能是正在使用中的火车、汽车、电车、船只、航空器等机动交通工具，即行为人的行为会导致不特定的多人轻重伤、死亡或者重大公私财产损害的交通工具（法益：公共交通运输安全）

（1）“正在使用中”：正在形势或者飞行中，待用、**备用**的交通工具。

2. 行为：破坏正在使用中的以上五种交通工具，已经造成或足以造成交通工具倾覆、毁坏危险的行为。

（1）破坏可以是有形破坏，也可能是外表完整无损，但是损坏其功能。

破坏尚未修好的汽车 不构成破坏交通工具罪，因为本身车的性能就不完备，也没有被认定为性能完备。

汽车修理工故意不修好汽车 构成，因为此处车子的性能在交付后被认定为性能完备。

（2）危险：具体危险，即在具体场合下对交通工具的破坏具有发生倾覆、毁坏的现实可能性。

在起飞前或者降落后打开安全门 对飞机只构成延误不构成倾覆的危险。

飞行过程中擅自打开安全门 构成，存在倾覆的危险。

3. 主体：一般主体

4. 责任要素：故意，包含直接故意和间接故意。

三、认定

1. 本罪 vs 破坏交通设施罪

行为对象不同。**毁坏移动铁路信号装置、拆卸铁轨、在铁轨上放置造成颠覆的危害物等应该被认定为破坏交通设施罪**

交通设施罪责任要素可以为过失

2. 本罪 vs 故意毁坏交通财物罪

是否足以危害公共安全。

第四十三章 交通肇事罪

第一百三十三条 【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处3年以上7年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处7年以上有期徒刑。

一、概述

违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，只认重伤、死亡或者公司财产遭受重大损失的行为。

二、概述

1. 对象（法益：交通运输安全）

2. 行为：因违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者公私财产遭受重大损失。

（1）张三先超速后正常速度，突然草丛钻出一个小孩，张三来不及刹车，就将其撞死了。不能认定交通肇事罪。该交通肇事罪管制的是因为违章作出“难以作出反应、难以刹车”等动作的行为。

（2）交通包括水上运输的船舶。（但是注意：若是违反安全管理法规是适用重大责任事故罪）

3. 主体：一般主体，一般是驾驶人。

并不特指驾驶人，也可以是车主、乘车人等

4. 责任要素：对违章可能是明知故犯，但对发生的后果必须是过失。（否则不能定此罪）

三、认定

1. 司法解释中的交通事故“责任”认定模式

认定交通肇事罪时，主要依据“行为之交通违章程度”认定“事故责任大小”，从而认定是够成立犯罪以及罪责的轻重。

2. 本罪与非罪的界限

交通肇事罪定罪处罚标准有二：（1）事故造成结果的大小（2）根据各方违章程度“认定或者分配”应该承担的事故责任。

3. 关于共犯的认定

交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处。

4. 关于指使他人违章驾驶的行为责任

单位主管人员、机动车辆所有人或者机动车辆承包人指使、强令他人违章驾驶造成重大交通事故的，以交通肇事罪定罪处罚。

5. 关于交通肇事后隐藏、一汽被害人致其死亡、伤残的罪责

构成不作为故意杀人/故意伤害罪定罪处罚。

行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃致使被害人无法得到救治而死亡或者严重残疾的，应当分别依照《刑法》第232条、第234条第2款的规定，以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。

6. 交通肇事罪 vs 重大责任事故罪等过失犯罪的界限

是否发生“实行公共交通的范围内”。如果在实行公共交通管理范围外，因为违反工作责任规章等造成重大损害，应当认定为重大责任事故罪。

7.★★★司法解释：（1）转化故意杀人或故意伤害（把被害人带离肇事地点，造成被害人死亡）；（2）交通肇事罪主体范围扩大化，包含行人、乘车人（其交通肇事罪成立要件必须是发生交通事故后即行为人违章在先，指使逃逸，导致被害人得不到救助死亡-死亡与逃逸有因果关系）、机动车所有人、承包人

四、处罚

犯本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

交通肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处3年以上7年以下有期徒刑。“交通运输肇事后逃逸”，是指行为人违反交通运输管理法规，在发生交通事故后，为逃避法律追究而逃跑的行为。“其他特别恶劣情节”，是指交通肇事具有下列情形之一的：死亡2人以上或者重伤5人以上，负事故全部或者主要责任的，死亡6人以上，负事故同等责任的；造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在60万元以上的。

（1）“逃逸”：行为人违反交通运输管理条例，发生交通事故后，为了逃避法律追究而逃跑的行为。

以交通肇事行为构成犯罪为前提。

因逃逸致人死亡的，处7年以上有期徒刑。

（2）“因逃逸致人死亡”：行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。（核心：逃逸行为与死亡之间存在因果关系）

例1 张三开着货车，在拐弯的时候“咯噔”一声，以为碾了一块石头，没多想就开走了。回到家发现轮胎上有血，回忆起刚才的咯之处，开着车返回，发现那旁边围着许多警察，他很害怕就走了。其实被害人在被撞时就死了。不构成，因为逃逸之前就死亡了。

例2 李四开车把人撞了，误以为被害人已死，下车拨打110报警电话，但是自始至终没有透露自己的个人信息。案发地离警察局有点远，警察花了2小时才赶到案发现场，被害人因在此期间无人救助死亡。在警察赶来之前，李四跑了，第天下午4点李四投案自首。如果赶着送到医院也救不活的情况下，可以否认逃逸和死亡的因果关系。如果可以救活，就存在不作为，存在因果关系。

最高法院在《刑事审判参考》1116号邵太平交通肇事案的指导案例中明确指出：“因逃逸致人死亡”的认定，不以逃逸前的交通肇事行为构成犯罪为前提”。（交通肇事罪不是逃逸致人死亡的前提，即在无法证明肇事时将被害人撞至重伤的程度情况下，也可以认定逃逸致人死亡）

例3 甲开车在外环路上撞了人，属于快车道，车流量极大。甲没有采取任何措施直接跑了，5分钟后另外一辆车把躺在地上的伤者碾死了。等于将被害人遗弃在难以获得救助甚至致死率极高的场景，应当认定为不作为的故意杀人。

例4 甲在普通道路上撞人，被害人躺在路上，半小时后乙从此处经过，再次碾压被害人。结果查明（1）乙碾压之前被害人就死了，也就是被害人死于第一次撞击。最多认定为甲交通肇事逃逸，因为死亡结果和逃逸没有因果关系。（2）因为乙的碾压被害人死亡了。认定甲交通肇事罪逃逸致人死亡，因为存在因果关系。（3）结果无法认定。有利于被害人原则，认定交通肇事逃逸。

第四十四章 危险驾驶罪

一、概述

在道路上驾驶机动车，有《刑法》第133条之一规定的危险驾驶情景之一的行为。

二、构成

1. 对象（法益：道路交通安全管理制度以及行人人身、车辆及其他公共设施的安全）
2. 行为：在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的；醉酒驾驶机动车的；从事校车业务或者旅客运输，严重超过定额乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危害公共安全的行为。
3. 主体：一般主体
4. 责任要素：故意。

三、认定

1. 本罪 与 非罪的界限
较轻情节：短距离挪车等
2. ☆ 本罪是交通肇事罪 不以发生重大交通事故为要件的 特殊类型
交通肇事罪又是114、115以危险方法危害公共安全罪的 特殊类型
致人死伤一般是交通肇事罪，只有认定行为人对于致人死伤有所故意，才能认定为以危险方法危害公共安全罪。
3. 醉驾认定
 - (1) 醉驾 vs 交通肇事罪
 - (2) 醉驾 vs 以危险方法危害公共安全罪
4. 本罪罪数形态

第四十五章 妨害安全驾驶罪

一、概述

对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的行为。

二、概述

1. 行为：（1）乘客打司机、抢夺方向盘（2）司机打乘客

三、认定

1. 本罪 vs 危险方法危害公共安全罪

属于竞和

2. 本罪 vs 劫持汽车罪

3. 本罪 vs 交通肇事罪

华东政法大学 法律学院 240101021016

第四十六章 反恐法

恐怖主义犯罪 (回去自己看)

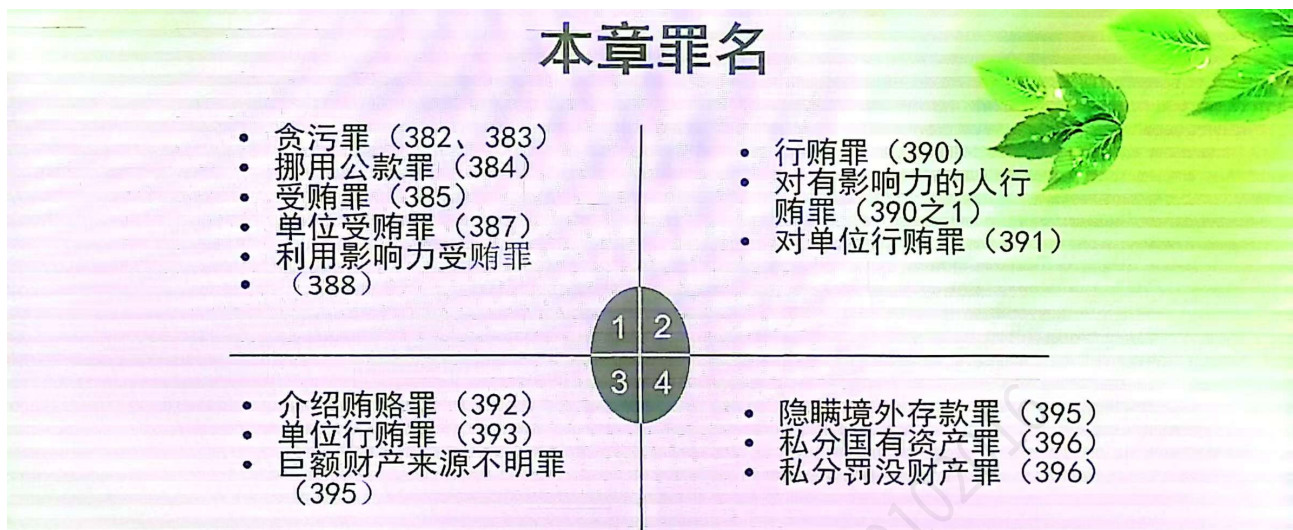
刑法120条-刑法120条之6

暴恐音频视频，持有就构成犯罪。

华东政法大学 法律学院 240101021016

第五讲 贪污贿赂罪

国家安全中的政治安全→必须站在国家、民族的高度理解贪污贿赂犯罪。



修法背景——四则案例

2014年系2015年颁布贪污受贿罪司法解释之前——

【案例 1】2014，重庆，被告人多次收受他人贿赂39万元，法院认定其有自首情节，且积极退赃，最终量刑6年6个月

【案例 2】2014，河北，被告人慈某多次收受他人贿赂5.8万元，法院认定其具有坦白情节，最终量刑6年

【案例 3】云南思茅地区（普洱）景谷县县委书记武某受贿10万元，最终量刑10年有期徒刑

【案例 4】青海省投资有限公司总经理孙某受贿168.6万元，最终量刑10年有期徒刑——处罚重；没有体现刑法中的“公平”。

几最：刑法处罚重、监督机构多、制度设计完美

1. 数据：2009-2014全国职务犯罪案件32439件增至41487件，增长率为27.89%，涉案人数从41531增至55101，增长32.67%。

对比：日本全国，2009-2014年受贿案件38/41/36/31/25/292。比率远低于中国。

2. 原有条文设计单纯计赃论罪(刑)的立法模式缺乏相对合理性。特别是“情节”要素没有充分发挥其在“量刑”中的作用。“数额中心论”的观念影响(郑筱萸案件)。

【郑筱萸案】——不能仅仅以数额判断危害性

单纯只考虑数额，而没有考虑被交易的权力。

3. 财产刑中的“罚金刑”应广泛适用于贪利型犯罪。

4. “宽严相济”刑事政策。

5. 严密刑事法网

6. 按照党的十八届三中全会对加强反腐败工作，完善惩治腐败法律规定的要求，加大惩处腐败犯罪力度。

完善贪污贿赂犯罪的方向

一、进一步完善了贪污受贿犯罪的定罪量刑标准，由以前规定的单纯的数额标准，这次修改完善为数额加情节的标准，以更符合实际情况，更好地做到罪刑相适应。

二、对重特大贪污受贿犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子增加规定了可以终身监禁的措施。应当强调的是这种措施不是一个新的刑种，它的对象只是针对贪污受贿被判处死缓的犯罪分子在具体执行中的一个特殊的措施。

三、加大了对行贿犯罪的处罚力度，主要是严格了行贿犯罪从宽处罚的条件。原来的法律规定是被追诉前主动交待的可以减轻和免除处罚，现在这个规定一般只能从轻和减轻处罚二是严密了惩治刑事犯罪的法网，只有对于有重大立功表现等几种情况可以免除处罚。增加规定了像国家机关工作人员的近亲属等特定关系人行贿的犯罪。三是增加规定了财产刑

· 《刑法修正案九》第10条、第44条、第45条、第46条、第47条、第48条、第49条。

· 涉及《刑法》条文第164条第1款、第383条、第390条、第390条之一(增设)、第391条第1款、第392条第1款、第393条。

· 1、条文变化 2、立法背景 3、争议问题4、司法适用(解释)5、存在疑问

刑法修正案九对贪污贿赂犯罪的修订

1. 刑事法网的严重化
2. 刑事政策的立法化
3. 处罚范围的扩大化
4. 处罚力度的严厉化
5. 刑事立法的科学化
6. 具体数额的抽象化

第四十七章 贪污罪

一、概述

第三百八十二条 【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。

受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。

与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处（注意规定）。

第三百八十三条 【对犯贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：

(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。

犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。

犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行2年期满后依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

第三百九十四条 【贪污罪】国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。（*注：区分受贿罪。核心：所有在国内公务活动或者对外交往中，对方赠予礼物的对象是国家。）

二、认定

1. 对象：公共财物（注意第382条第2款规定）

第九十一条 【公共财产的范围】本法所称公共财产，是指下列财产：

(一)国有财产；

(二)劳动群众集体所有的财产；

(三)用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。

在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。

2. 主体的范围：（除共犯）国家工作人员（注意第382条第2款、第271条第2款的特殊规定）

第九十三条 【国家工作人员的范围】本法所称国家工作人员，是指国家机关（权利机关、行政机关、司法机关、监察机关、军事机关、参政议政机关政协、中国共产党各级委员会）中从事公务的人员。

国有公司、企业、事业单位、人民团体（财政纳入本级财政预算上海市法学会）中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社

会团体（在本级的民政局做过登记备案）从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。

→ 国有公司：

- 国家全资企业
- 国有控股企业：绝对控股（51%）；相对控股（多股东，国资占比较高）
- 国家出资企业（占比再少也是国家工作人员）

→ 村委会、居委会（群众自治组织）：

在代表上一届政府实施职权时，当成国家工作人员。

村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：

- （一）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；
- （二）社会捐助公益事业款物的管理；
- （三）国有土地的经营和管理；
- （四）土地征用补偿费用的管理；
- （五）代征、代缴税款；
- （六）有关计划生育、户籍、征兵工作；
- （七）协助人民政府从事的其他行政管理工作。

村民委员会等村基层组织人员从事前款规定的公务，利用职务上的便利，非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物，构成犯罪的，适用刑法第三百八十二条和第三百八十三条贪污罪、第三百八十四条挪用公款罪、第三百八十五条和第三百八十六条受贿罪的规定。

→ 利用职务便利：

【最高院指导案例11号：杨延虎等贪污案】

被告人杨延虎1996年8月任浙江省义乌市委常委，2003年3月任义乌人大常委会副主任，2000年8月兼任中国小商品城福田市场（2003年3月改称中国义乌国际商贸城，简称国际商贸城）建设领导小组副组长兼指挥部总指挥，主持指挥部全面工作。2002年，杨延虎得知义乌市稠城街道共和村将列入拆迁和旧村改造范围后，决定在该村购买旧房，利用其职务便利，在拆迁安置时骗取非法利益。杨延虎遂与被告人王月芳（杨延虎的妻妹）、被告人郑新潮（王月芳之夫）共谋后，由王、郑二人出面，通过共和村王某某，以王月芳的名义在该村购买赵某某的3间旧房（房产证登记面积61.87平方米，发证日期1998年8月3日）。按当地拆迁和旧村改造政策，赵某某有无该旧房，其所得安置土地面积均相同，事实上赵某某也按无房户得到了土地安置。

2003年3、4月份，为使3间旧房所占土地确权到王月芳名下，在杨延虎指使和安排下，郑新潮再次通过共和村王某某，让该行村民委员会及其成员出具了该3间旧房系王月芳1983年所建的虚假证明。杨延虎利用职务便利，要求兼任国际商贸城建设指挥部分管土地确权工作的副总指挥、义乌市国土资源局副局长吴某某和指挥部确权报批科人员，对王月芳拆迁安置、土地确权予以关照。国际商贸城建设指挥部遂将王月芳所购房屋作为有村证明但无产权证的旧房进行确权审核，上报义乌市国土资源局确权，并按丈量结果认定其占地面积64.7平方米。

此后，被告人杨延虎与郑新潮、王月芳等人共谋，在其岳父王某祥在共和村拆迁中可得25.5平方米土地确权的基础上，于2005年1月编造了由王月芳等人签名的申请报告，谎称“王某祥与王月芳共有三间半房屋，占地90.2平方米，二人在1986年分家，王某祥分得36.1平

方米，王月芳分得54.1平方米，有关部门确认王某祥房屋25.5平方米、王月芳房屋64平方米有误”，要求义乌市国土资源局更正。

核心问题：“利用职务便利”是主管、管理、经手。此时杨延虎作为人大副主任，不主管相关方面。

【裁判结果】

浙江省金华市中级人民法院于2008年12月15日作出(2008)金中刑二初字第30号刑事判决：一、被告人杨延虎犯贪污罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产十万元；决定执行有期徒刑十八年，并处没收财产三十万元。二、被告人郑新潮犯贪污罪，判处有期徒刑五年。、被告人王月芳犯贪污罪，判处有期徒刑三年。宣判后，三被告人均提出上诉。浙江省高级人民法院于2009年3月16日作出(2009)浙刑二终字第34号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。

【裁判要点】

1. 贪污罪中的“利用职务上的便利”：

是指利用职务上主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件，既包括利用本人职务上主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件，也包括利用职务上有隶属关系的其他国家工作人员职务便利。

2. 土地使用权具有财产性利益，属于刑法第三百八十二条第一款规定。

三、变化

原文	草案	二审稿	定稿
第三百八十三条 对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。（四）个人贪污数额不满五千元，情节较轻的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。	第三百八十三条 对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。尚不构成犯罪的，由其所在单位或者上级主管机关给予处分。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第（一）项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第（二）项、第（三）项规定情形的，可以从轻处罚。	第三百八十三条 对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。尚不构成犯罪的，由其所在单位或者上级主管机关给予处分。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第（一）项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第（二）项、第（三）项规定情形的，可以从轻处罚。	第三百八十三条 对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。删除了后半句。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第（一）项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第（二）项、第（三）项规定情形的，可以从轻处罚。情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

· 1997年：由重到轻的排序；贪污处罚规定很重

· 草案：

调整由轻到重的排列（反应贪污罪在形势政策的变化轻的一面——之前过度依赖刑罚的方式需要调整）；

在从轻减轻情节加了时间要素“提起公诉前”；

提高入罪门槛：3万以下由党纪政纪管理、可以（没有特殊情况就应该）从轻减轻或者免除处罚（相对不起诉）——在刑法的溯源端解决问题-预防（零狱空虚）

· 定稿：

加入「终身监禁」。

第三百八十三条 【对犯贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：

- (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
- (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产（说明没收财产并不是针对无期徒刑和死刑的专用刑）。
- (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。

【特别从宽处罚条款-降低犯罪数量】犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。

犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行2年期满后依法减为无期徒刑后（*终身监禁是在第一次宣判就明确，不是死缓减为无期徒刑后），终身监禁，不得减刑、假释。

【讨论】设置“终身监禁”制度

- 终身监禁在世界范围一般适用罪行极其严重的暴力犯罪，中国仅仅适用在职务犯罪
- 终身监禁制度是否成为“宣示性”立法？是否为将来废除贪污贿赂犯罪死刑作为铺垫？

观点一：终身监禁制度是死刑保留的替代措施，减少死刑的实际适用。

观点二（李翔）：立法上保留死刑，司法上严格限制死刑。主张应当废除死刑，因为死刑应当适用于危害重大国家利益的犯罪，不赞成在经济犯罪中保留死刑

(1) 死刑作为最残酷的刑罚，国际社会认为对经济类犯罪和职务犯罪保留死刑缺乏正当性（eg：集资诈骗）

(2) 贪污受贿保留死刑在追逃追赃中导致制度性障碍：引渡。国际社会政治犯和死刑犯不引渡（eg：过去的走私罪-也有死刑）

“红通”-劝返：外交承诺不适用死刑；在国外活不下去了

(3) 社会民意：民众对于社会贪污受贿的感知来自于自己没有获得权力和财富，而不是对社会危害度有感知（不理性人）——民意的假象

四、关于“数额”问题

数额由具体变为巨额、巨大、特别巨大，概括数额在司法实践中具体掌握，如何进一步明确制定具体数额标准？

【北京市公安局丰台分局副局长受贿案】

贪污罪：【1】数额较大(3-20万)，其他较重情节:数额(1-3万)+情节【（一）特定对象贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；（二）之前没定罪现在定曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；（四）赃款赃物用于非法活动如赌博嫖娼的；（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的】。

【2】数额巨大(20-300万)，其他严重情节：数额(10-20万)+情节

【3】数额特别巨大(300万以上)，其他特别严重情节:(150-300万)+情节

注：情节犯中的情节，还是考虑数额

第四十八章 受贿罪

第三百八十五条 【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

第三百八十六条 【对犯受贿罪的处罚规定】对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。

第三百八十七条 【单位受贿罪】国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。

前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。

第三百八十八条 【受贿罪】国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。

第三百八十八条之一 【利用影响力受贿罪】国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处7年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的，依照前款的规定定罪处罚。

一、认定

1. 三种行为方式：索贿（包括勒索贿赂）、被动收受、斡旋受贿（不是利用本人职务便利，而是利用本人的职务影响通过其他人的职务便利）

2. “财物”：具有价值的可以归你了的有体物、无体物以及财产性利益。

→“财产性利益”：（游贿案件）行为人请国家工作人员出去旅游的行为，如果被接受，也应当认定为受贿；

* 房子、汽车不要求实际过户

【问题】性贿赂属不属于财产性受贿？

通说：不是。因为不属于财产性利益。

李翔：在游贿案中的性贿赂有可能被综合认定为财产刑受贿

3. “为他人谋利”（司法解释）：国家工作人员许诺为他人谋利，而不能要求是实实在在地谋取了利益（不需要“着手”）（联合国反腐败公约中存在：许诺、实施、实现三种，完成一种都属于）。这里的许诺既可是明示的，也可以是暗示的。

在司法中的推定：行为人明知他人有请托事项，没有拒绝就视为同意。

4. 索取或收受贿赂：并不限于行为人将贿赂直接据为己有，而是**包括使请托人向第三者提供贿赂**的情形

雅贿：溜须拍马情商式的行贿。“（一个破瓷器）哎呀我买这个用20万你还亏了”

二、关于“解释”的新问题

1. 解释

【解释的扩大化】（一）实际或者承诺为他人谋取利益的；（二）明知他人有具体请托事项的；（三）**履职时未被请托，但时候基于该履职事由收受他人财物的**——“事后”的理解。
采购部经理选A公司，事后A公司来感谢他给钱，经理知道为什么给钱的

【解释的刑事推定】**特定关系人索取、收受他人财物，国家工作人员知道后未退还或者上交的**，应当认定国家工作人员具有受贿故意（第16条第2款）

→“特定关系人”：近亲属（父母、配偶、子女）+有共同利益关系的情人

是指“知道还不退还上交”，以此推定受贿。但是本人若产生错误认识，客观没有上交退还，那也不能从结果推定。

李翔：受贿不应该仅限于直接故意，也应该包含间接故意（放任）

→“收受他人财物，**及时**上交或者退还”：“及时”是指**行为人缺乏受贿故意，不是时间的概念**
· 为什么要特定设置这个“出罪路径”：中国会出现收钱≠受贿的情况，如饭不得不吃但没有受贿故意。

2. 【财物】包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。后者的犯罪数额，以实际支付或者应当支付的数额计算。

3. 【故意的认定】国家工作人员出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物、收受他人财物之后，**将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的**，不影响贪污罪、受贿罪的认定，但量刑时可以考虑。

4. 【解释的政策化】（感情投资）**国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。**（第13条第2款）

· 人情往来与受贿的关系：行为人对财物价值认知可能性（结合行为人的教育背景、社会背景、社会认知）：若对物的客观价值认知缺乏可能性，不能单独基于数额定罪。字画——只要求行为人有**概括认知**，也不要具体数额（2）现实情况礼物价值可能不对等-限制性解释思路：数额限制在**同一类对象主体**之间。司法实践中这种**不按刑事犯罪按照违纪**。

第四十九章 行贿罪

第三百八十九条 【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

第三百九十条 【对犯行贿罪的处罚】对犯行贿罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

有下列情形之一的，从重处罚：

- (一) 多次行贿或者向多人行贿的；
- (二) 国家工作人员行贿的；
- (三) 在国家重点工程、重大项目中行贿的；
- (四) 为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；
- (五) 对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；
- (六) 在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；
- (七) 将违法所得用于行贿的。

行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

第三百九十条之一 【对影响力人行贿罪】为谋取不正当利益，向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处7年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

第三百九十一条 【对单位行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第三百九十二条 【介绍贿赂罪】向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。

第三百九十三条 【单位行贿罪】单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

刑法修正案（十二）前、中、后对照表

第三百九十条 行贿罪	对犯行贿罪的，处 五年 以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处 五年 以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。	对犯行贿罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。具有下列情形之一的，依照前款的规定从重处罚： (一) 多次行贿、向多人行贿的； (二) 国家工作人员行贿的； (三) 在国家重要工作、重点工程、重大项目中进行行贿的； (四) 在组织人事、执纪执法司法、生态环保、财政金融、安全生产、食品药品、帮扶救灾、养老社保、教育	对犯行贿罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。有下列情形之一，从重处罚： (一) 多次行贿或者向多人行贿的； (二) 国家工作人员行贿的； (三) 在国家重点工程、重大项目中进行行贿的； (四) 为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；
---------------	---	--	---

刑法修正案（十二）前、中、后对照表

医疗等领域行贿的； (五) 为实施违法犯罪活动而行贿的； (六) 将违法所得用于行贿的。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。	(五) 对监察、行政执法、司法工作人员行贿的； (六) 在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾减灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的； (七) 将违法所得用于行贿的。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
--	---

- 草案“多次行贿、向多人行贿的”→“多次行贿或者向多人行贿的”
- 谋取职务：包含平级之间的“调整”
- 行贿人的从轻减轻处罚：原来是从轻减轻或者免除处罚，比自首（从轻或减轻处罚）轻；刑法修正案九中改为“从轻或减轻处罚”，必须有三种情形的才能免除处罚。

1. 行贿罪的法益（——进而了解行贿的刑罚配置如何更加合理）

(1) 行贿罪和受贿罪的法益同一性：职务行为的不可收买性和职务行为的公正性（行贿就是用财产去购买权力性利益，而权力应当是由全国公民共同享有）

(2) 行贿罪和受贿罪的社会危害性比较：对受贿的处罚应当重于行贿

① 不能单纯从数额角度决定其社会危害性及程度——**权力交易之后社会民众干制度是不一样的**

② 谁对出卖职务行为具有决定权——受贿人，权力所有者

③ 谁的行为对法益侵害更具直接性——运用权力的人，即受贿人

④ 谁更具有廉洁责任义务——每个人都可能是行贿人，受贿人相较更少。**不能把心思放在招投标的机会上，而应当是招投标的工程质量上。**

· 有些人不是真心实意的要行贿，是因为在愿意接受受贿的人面前，为了获得机会不得不行贿。

⑤ 中国古代及近现代的刑法规定

⑥ 国外的刑法规定

由于不能否认行贿罪是受贿罪的共犯行为，因而其法定刑减轻的根据是，从官僚具有强大的统制力的我国传统来看，一般来说，考虑到相对于受惠者而言行贿者处于相对弱势的地位，其责任得以类型性的减轻。

——〔日〕西田典之

2. 刑事政策

2021.9 中央纪委国家监委与中央组织部、中央统战部、中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院联合印发了《关于进一步推进行贿受贿一起查的意见》

- 行贿罪特殊的对行性犯罪
- 为什么行贿的对行性要按照异罪处理
- 还有什么别的处理方式
(lx老师最新的文章)

第五十章 挪用公款罪

第三百八十四条 【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的，是挪用公款罪，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处5年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

一、认定

1. 行为：挪用公款归个人使用

(1) 必须要有使用（不光挪还得用，才能构成）

不具非法占有目的【区别于贪污罪】

(2) “个人”：有所扩大

① 供本人或其他自然人使用

② （单位1）以个人名义挪用给单位使用

③ （单位2）个人决定以单位名义挪用给单位使用

(3) “使用”的用途：

① 非法活动：无数额和时间的要求；数罪并罚

② 盈利活动：有数额较大要求，无时间要求

③ 其他活动：有数额较大要求，挪用超过三个月

(4) 数罪并罚问题：因挪用公款索取、收受贿赂（源头是受贿，后端是挪用公款）构成犯罪的，挪用公款进行非法活动构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚

(5) “挪用公款数额巨大不退还的”：不是主观上不想退换（否则就是贪污了），而是客观上不能退还——结果加重（挪用公款不具有非法占有目的，主观上不想退换就是具有非法占有目的，系贪污）

时间要素：一审宣判前不能退还

(6) 挪用公款罪的转化犯

对下列行为，应以贪污罪（本质：非法占有目的）论处（可推定有非法占有目的）：

① 携带挪用的公款潜逃的

② 挪用公款后采取虚假发票平账、销毁有关账目等手段，使所挪用的公款已难以反映在单位财务账目上，且没有归还行为的。

③ 截取单位收入不入账，非法占有，使所占有的公款难以反映在单位财务账目上，且没有归还行为的。

④ 有证据证明行为人有能力归还所挪用的公款而拒不归还，并隐瞒挪用的公款去向的。

二、挪用公款罪的疑难问题

(1. 要注意挪用公款三种用途的使用条件，未达到不作为犯罪。)

2. 挪用公款归还个人欠款的，应当根据产生欠款的原因，分别认定属于挪用公款的何种情形。

赌债——产生原因：赌博——非法活动——挪用公款从事非法活动。

挪用去买股票——产生原因：股票——挪用公款进行盈利活动

3. 对挪用公款罪的用途认定，应根据客观的使用性质予以判断。

要看最终在客观上用在哪里。

4. 行为人挪用公款分别用于非法活动、盈利活动与其他活动，用于某项活动的公款数额未达到该项的定罪标准，但挪用公款的总数额达到某项定罪标准的，应当如何处理？

非法活动本身具有不法性，所以其入罪标准应该更低，则三种用途的标准不可能统一，统一则缺乏实质公正。

【案例】

甲前后两次都不达到，总额达到。

乙挪用从事非法活动7000元、从事盈利活动25000元，总体达到了其他活动的数额入罪标准。

实践中观点一：都不定罪

观点二：都定罪

→反驳：存疑有益于被告人原则

李翔：存疑有益于被告人原则应当是事实存疑（此处事实不存疑），法律存疑是正常的。

对非法数额的评价是更负面的，不能把其他活动的数额用在非法数额的累积计算上，这对行为人是^不利的，也从性质上改变了非法活动；相反，如果把非法活动数额用于盈利活动数额是可以的。

不能乙非法活动25000元，丙5000元，前后都不定罪。

第五十一章 利用影响力受贿罪

第三百八十八条之一 【利用影响力受贿罪】国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处7年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的，依照前款的规定定罪处罚。

一、认定

1. 主体：非国家工作人员

≠国家工作人员以外的都是

A是请托人，找非国家工作人员但是是国家工作人员乙的近亲属甲，后又借另一个国家工作人员丙的职权办事。

2. 行为：谋取不正当利益

【沪首例利用影响力受贿案】

2016年5月19日，普陀区检察院对朱某某立案侦查。经调查，朱某某与国家工作人员叶某(另案处理)相识二十多年，且关系密切。2015年9月，朱某某受白某请托，利用叶某的职务行为，为白某谋取不正当利益，并收取自某好处费人民币10万元。2016年7月27日，因朱某某涉嫌利用影响力受贿罪，被普陀区人民检察院提起公诉，法院将对此案择日宣判。

本案中，朱某某与叶某系同乡，已相识二十多年。两家人之间经常互相走动、聚餐、去外地旅游。在一定范围内，两人的密切关系也被周围人所知晓。也正因为如此，本案中白某才会来请托朱某某，利用叶某的职权帮忙谋取不正当利益。

朱某某虽非国家工作人员，但利用了叶某职务上的行为，为自某谋取不正当利益，并收受请托人白某所支付的10万元感谢费。朱某某的行为侵犯了国家机关的正常管理活动和公众对国家机关工作人员依法、廉洁办事的信赖，损害了国家工作人员的廉洁形象。

第五十二章 其他

1. 对影响力的人行贿罪

第三百九十条之一 【对影响力的人行贿罪】为谋取不正当利益，向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处7年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

(1) 法定最高刑：十年——和行贿罪有较大区别

(2) 谋取不正当利益

(3) 没有特别从宽处罚

【讨论】390条中的特别从宽处罚（追诉前主动交代行贿行为…）条款能不能适用于390条之一的对影响力的人行贿罪？

观点一：将390条之一当成390条的派生条款

李翔：这不符合常识。确实“之x”的条款要考虑“本条”的密切关系（甚至法益相同），但是“之”条与本条不是隶属关系，而是独立关系。

李翔：之所以有这个问题，是因为对于同样的行贿类案件中为什么对行贿设置特别从宽对影响力受贿不设置，本质在最终都是利用国家利益。所以此时要考虑一个体系化问题，不仅仅是行贿，而且还有163、164也没有特别从宽。

2. 单位行贿罪

李翔：《论贿赂犯罪刑罚结构的体系性优化》

第三百九十一条 【对单位行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。

第三百九十三条 【单位行贿罪】单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

(1) 将单位犯罪单独单列出一条，而不是款

3. 巨额财产来源不明罪；隐瞒境外存款罪

4. 私分国有资产罪；私分罚没财物罪

(1) 认识上不宜当作单位犯罪处理

第六讲 渎职罪

第五十三章 滥用职权罪；玩忽职守罪

第三百九十七条 【滥用职权罪；玩忽职守罪】国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定（说明本条款为概括性条款，那么397条以下构成相应犯罪时就要用相应罪名进行调整，不能适用第397条——普通条款）。

国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

1. 主体：国家机关工作人员（非“国家工作人员”）

国家工作人员包含国家机关工作人员

【问题】渎职是强调身份还是行为呢？——人大常委会通过立法解释强调行为是与职权的运行有关，而不是与身份有关（理想状态是职权运行和身份高度统一）

eg. 指挥交通的社区志愿者 & 指挥交通的警察

(1) 扩大1：虽未列入国家机关工作人员编制，但在国家机关中从事公务的人员
书记员

(2) 扩大2：在受国家机关委托从事行政管理的组织中从事公务的人员

卫生健康委员会（国家机关）授权卫生委职权，那在卫生委工作中从事公务的人员是国家机关工作人员。

(3) 扩大3：依照法律法规拥有行政管理职权的组织中从事公务的人员

2. “徇私舞弊”作为情节加重犯，不单独作为罪名

3. 行为：

(1) 超越职权行使，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失

(2) 滥用职权罪属于作为犯罪；玩忽职守罪属于不作为犯罪（应当行使但不行使）

(3) 具体到人

4. 责任要素：（只有）过失

在明知自己权力的边界时（法律推定的），当超越职权行使就是故意，但是不代表就被定罪了，因为第387条中还有“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”，即结果犯。不能把滥用职权罪的主观罪过解释为故意，因为↓。如果行为人明知自己的行为会导致1人以上死亡，其中至少还有放任，那么此时按照滥用职权罪/玩忽职守罪认定，最低刑只有拘役。

最高人民法院 最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）

法释〔2012〕18号

第一条 国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”：

（一）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者轻伤9人以上，或者重伤2人、轻伤3人以上，或者重伤1人、轻伤6人以上的；

（二）造成经济损失30万元以上的；

（三）造成恶劣社会影响的；

（四）其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“情节特别严重”：

（一）造成伤亡达到前款第（一）项规定人数3倍以上的；

（二）造成经济损失150万元以上的；

- (三) 造成前款规定的损失后果，不报、迟报、谎报或者授意、指使、强令他人不报、迟报、谎报事故情况，致使损失后果持续、扩大或者抢救工作延误的；
- (四) 造成特别恶劣社会影响的；
- (五) 其他特别严重的情节。

【区别】过失致人死亡罪

滥用职权只是过失致人死亡的手段？——公职人员滥用职权过失致人死亡的法定刑低于一般过失。

正当性在于？——保护履职的积极性。

第二百三十三条 **【过失致人死亡罪】** 过失致人死亡的，处3年以上7年以下有期徒刑；情节较轻的，处3年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

第五十四章 徇私枉法罪

第三百九十九条 【徇私枉法罪】司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑；情节特别严重的，处10年以上有期徒刑。

一定是在刑事案件当中。

→进而才相较于下面的民事、行政案件而言有更高的法定刑和更多的层次。

【民事、行政枉法裁判罪】在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。

【执行判决、裁定失职罪；执行判决、裁定滥用职权罪】在执行判决、裁定活动中，严重不负责任或者滥用职权，不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责，或者违法采取诉讼保全措施、强制执行措施，致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；致使当事人或者其他人的利益遭受特别重大损失的，处5年以上10年以下有期徒刑。

【择一重处】司法工作人员收受贿赂，有前三款行为的，同时又构成本法第三百八十五条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

此时的徇私枉法行为本身就等于受贿中“为他人谋取利益”，进而受贿罪构成要件中的为他人谋取利益的行为。此时受贿罪复合行为中的部分行为和徇私枉法的行为产生竞合。如果数罪并罚，那么会导致徇私枉法行为被重复评价。所以此时只能采取竞合的处罚原则——从一重处。

在刑法分则第九章中，除第399条这些人收受贿赂是从一重处之外，所有收受贿赂的，行为人一律实行数罪并罚。

第三百九十九条之一 【枉法仲裁罪】依法承担仲裁职责的人员，在仲裁活动中故意违背事实和法律作枉法裁决，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。

【王立军徇私枉法逃案】

第五十五章 其他

第三百九十八条 【故意泄露国家秘密罪；过失泄露国家秘密罪】国家机关工作人员违反保守国家秘密法的规定，故意或者过失泄露国家秘密，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。

非国家机关工作人员犯前款罪的，依照前款的规定酌情处罚。

第四百条 【私放在押人员罪】司法工作人员私放在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑；情节特别严重的，处10年以上有期徒刑。

【失职致使在押人员脱逃罪】司法工作人员由于严重不负责任，致使在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯脱逃，造成严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；造成特别严重后果的，处3年以上10年以下有期徒刑。[18]

第四百零一条 【徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪】司法工作人员徇私舞弊，对不符合减刑、假释、暂予监外执行条件的罪犯，予以减刑、假释或者暂予监外执行的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第四百零二条 【徇私舞弊不移交刑事案件罪】行政执法人员徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役；造成严重后果的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第四百零三条 【滥用管理公司、证券职权罪】国家有关主管部门的国家机关工作人员，徇私舞弊，滥用职权，对不符合法律规定条件的公司设立、登记申请或者股票、债券发行、上市申请，予以批准或者登记，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役。

上级部门强令登记机关及其工作人员实施前款行为的，对其直接负责的主管人员，依照前款的规定处罚。

第四百零四条 【徇私舞弊不征、少征税款罪】税务机关的工作人员徇私舞弊，不征或者少征应征税款，致使国家税收遭受重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑。

第四百零五条 【徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪】税务机关的工作人员违反法律、行政法规的规定，在办理发售发票、抵扣税款、出口退税工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处5年以上有期徒刑。

【违法提供出口退税证罪】其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。[18]

第四百零六条 【国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪】国家机关工作人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第四百零七条 【违法发放林木采伐许可证罪】林业主管部门的工作人员违反森林法的规定，超过批准的年采伐限额发放林木采伐许可证或者违反规定滥发林木采伐许可证，情节严重，致使森林遭受严重破坏的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

第四百零八条 【环境监管失职罪】 负有环境保护监督管理职责的国家机关工作人员严重不负责任，导致发生重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者造成人身伤亡的严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

第四百零八条之一 【食品、药品监管渎职罪】 负有食品药品安全监督管理职责的国家机关工作人员，滥用职权或者玩忽职守，有下列情形之一，造成严重后果或者有其他严重情节的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成特别严重后果或者有其他特别严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑：

- (一) 瞒报、谎报食品安全事故、药品安全事件的；
- (二) 对发现的严重食品药品安全违法行为未按规定查处的；
- (三) 在药品和特殊食品审批评审过程中，对不符合条件的申请准予许可的；
- (四) 依法应当移交司法机关追究刑事责任不移交的；
- (五) 有其他滥用职权或者玩忽职守行为的。

徇私舞弊犯前款罪的，从重处罚。

第四百零九条 【传染病防治失职罪】 从事传染病防治的政府卫生行政部门的工作人员严重不负责任，导致传染病传播或者流行，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

第四百一十条 【非法批准征收、征用、占用土地罪；非法低价出让国有土地使用权罪】 国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征收、征用、占用土地，或者非法低价出让国有土地使用权，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家或者集体利益遭受特别重大损失的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第四百一十一条 【放纵走私罪】 海关工作人员徇私舞弊，放纵走私，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。

第四百一十二条 【商检徇私舞弊罪】 国家商检部门、商检机构的工作人员徇私舞弊，伪造检验结果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成严重后果的，处5年以上10年以下有期徒刑。

【商检失职罪】 前款所列人员严重不负责任，对应当检验的物品不检验，或者延误检验出证、错误出证，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

第四百一十三条 【动植物检疫徇私舞弊罪】 动植物检疫机关的检疫人员徇私舞弊，伪造检疫结果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成严重后果的，处5年以上10年以下有期徒刑。

【动植物检疫失职罪】 前款所列人员严重不负责任，对应当检疫的检疫物不检疫，或者延误检疫出证、错误出证，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役。[18]

第四百一十四条 【放纵制售伪劣商品犯罪行为罪】 对生产、销售伪劣商品犯罪行为负有追究责任的国家机关工作人员，徇私舞弊，不履行法律规定的追究职责，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役。

第四百一十五条 【办理偷越国(边)境人员出入境证件罪；放行偷越国(边)境人员罪】 负责办理护照、签证以及其他出入境证件的国家机关工作人员，对明知是企图偷越国(边)境的人员，予以办理出入境证件的，或者边防、海关等国家机关工作人员，对明知是偷越国(边)境的人员，予以放行的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第四百一十六条 【不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪】 对被拐卖、绑架的妇女、儿童负有解救职责的国家机关工作人员，接到被拐卖、绑架的妇女、儿童及其家属的解救要求或者接到其他人的举报，而对被拐卖、绑架的妇女、儿童不进行解救，造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役。

【阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪】负有解救职责的国家机关工作人员利用职务阻碍解救的，处2年以上7年以下有期徒刑；情节较轻的，处2年以下有期徒刑或者拘役。[18]

第四百一十七条 【帮助犯罪分子逃避处罚罪】有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。

第四百一十八条 【招收公务员、学生徇私舞弊罪】国家机关工作人员在招收公务员、学生工作中徇私舞弊，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

第四百一十九条 【失职造成珍贵文物损毁、流失罪】国家机关工作人员严重不负责任，造成珍贵文物损毁或者流失，后果严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

华东政法大学 法律学院 240101021016

(李翔) 设身处地换位思考处理案件，这是正义感。

刑法来自于生活，刑法学说正在由经验主义色彩向价值思索转变。

立法两原则：

法益保护原则：没有法益侵害 不得立法

比例原则：规定为犯罪要配置合理的法定刑

华东政法大学 法律学院 240101021016

考试

单选15题·1'多选5题（以案例为主） 名词解释解答题案例分析

国家工作人员【93】

背国家机关工作人员 5+2+3（人大以立法解释扩大国家机关工作人员范围）

第九十三条 【国家工作人员的范围】本法所称国家工作人员，是指国家机关（权利机关、行政机关、司法机关、监察机关、军事机关、参政议政机关政协、中国共产党各级委员会）中从事公务的人员。

国有公司、企业、事业单位、人民团体（财政纳入本级财政预算上海市法学会）中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体（在本级的民政局做过登记备案）从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。

→ 国有公司：

- 国家全资企业
- 国有控股企业：绝对控股（51%）；相对控股（多股东，国资占比较高）
- 国家出资企业（占比再少也是国家工作人员）

→ 村委会、居委会（群众自治组织）：

在代表上一届政府实施职权时，当成国家工作人员。

村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：

- （一）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；
- （二）社会捐助公益事业款物的管理；
- （三）国有土地的经营和管理；
- （四）土地征用补偿费用的管理；
- （五）代征、代缴税款；
- （六）有关计划生育、户籍、征兵工作；
- （七）协助人民政府从事的其他行政管理工作。

村民委员会等村基层组织人员从事前款规定的公务，利用职务上的便利，非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物，构成犯罪的，适用刑法第三百八十二条和第三百八十三条贪污罪、第三百八十四条挪用公款罪、第三百八十五条和第三百八十六条受贿罪的规定。

→ 扩大（3个）

（1）扩大1：虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，在代表国家机关行使职权

书记员

（2）扩大2：在受国家机关委托代表国家机关行使职权的**组织**中从事公务的人员

卫生健康委员会（国家机关）授权卫生委职权，那在卫生委工作中从事公务的人员是国家机关工作人员。

（3）扩大3：依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员

· 刑法分则体系依据什么来分10章节的，为什么要这样排列？

同类客体/法益（本科阶段可以在同一个意义上等同客体和法益概念）；但是存在单一客体和复杂客体（又分为主要次要客体，考虑二者关系）；并不是一章节中侵害的法益完全具有同等性，存在例外（**选择题**）。

（step 1）同类客体；（step 2）大体按社会危害性（但也存在例外，如醉酒驾驶放在第二章并不意味着就比后面的贪污贿赂社会危害性高）

刑法修正主要以修正案行使，但是也不是绝对的，还有「**补充规定**」。

· 法条竞合和想象竞合的区别以及对法条竞合

同时构成其他犯罪的xxx，此时可能构成法条竞合也有可能是想象竞合。

竞合在手段上、主体上、对象上都有可能

想象竞合是一种动态上的概念（一个行为触犯数个罪名）；而法条竞合是静态分析法条关系，分为包容竞合和交叉竞合。比如滥用职权罪和徇私枉法（滥用司法裁判权）罪典型的法条竞合，前者是一般法条（包括其法条中的“本法另有规定的…”），后者是特殊法条。

包容竞合 法条竞合中处断原则一是特别条款优于普通条款。此时特别条款被包容于普通条款，范围比普通条款小。

交叉竞合 情况二：法条中相互包容（交叉）。招摇撞骗行为类型被诈骗包容，诈骗范围更加宽泛。但是诈骗罪对象是财产性利益，但招摇撞骗对象不限于财产性利益。即诈骗罪的手段比招摇撞骗宽泛，但是对象比财产性利益小。此时出现第二原则：重罚优于轻罚——基于罪行均衡的需求（所以才不是轻罚由于重罚）。

找刑法分则条文中的例子，两种类型都要找，进而利用其进行原理说明

破坏交通工具罪 & 破坏交通设施罪

做到盗窃窃取性和破坏型财产犯罪时，注意留意犯罪对象，看是不是和公共安全有关联，进而看是不是构成这两个罪名（如翘起铁轨卖掉）

公共性都是体现在足以使交通工具造成倾覆、毁坏的危险（危险犯）。

此时产生法条竞合，这时候选择危害公共安全类犯罪，因为有死刑。

交通肇事罪

注意构成要件和司法解释

违反交通管理法规；一人死亡或者三人重伤，30万元。

司法解释：转化故意杀人或故意伤害（把被害人带离肇事地点，造成被害人死亡）；
交通肇事罪主体范围扩大化，包含行人、乘车人（其交通肇事罪成立要件必须是发生交通事
故后 即行为人违章在先，指使逃逸，导致被害人得不到救助死亡-死亡与逃逸有因果关系）、机动车所有人、承包人

二维码

给人虚假链接的最高人民法院指导性案例。一种构成盗窃罪，一种构成诈骗罪。

233过失致人死亡罪

渎职罪致人死亡、交通肇事罪致人死亡、重大责任事故罪——都是过失，均死亡结果作为犯罪成立条件。而233过失致人死亡是作为普通条款，当其他条款也规定了过失致人死亡，适用其他特别条款。

绑架罪

注意目的问题：分为绑架勒索型（获得财产性利益）；绑架人质型

特别在绑架勒索型中要考虑，如拐卖妇女儿童罪以出卖、勒索财物为目的拐卖婴幼儿，不同目的不同处罚。

绑架以绑架为目的，拐卖妇女儿童罪以出卖为目的。

入户抢劫

八种加重情节第一项就是入户抢劫

重要要素：以抢劫为目的。区别于其他目的与在户抢劫（在房子里临时起意抢劫）入的理解、户的理解、入户目的的要求；结合案例尤其防止“以xx名义”的问题

行贿罪

两个重要要素：（1）谋取不正当利益（受贿没有）（2）行贿罪特别从宽处罚条款（什么样情况下可以从轻或者减轻，什么情况可以减轻或者免除）

盗窃罪

盗窃的类型：公司财务数额较大；入户；多次盗窃；携带凶器；扒窃

注意“以受贿论”、“以贪污论”、“明知有损他人名誉…以捏造并散布论”等等

本质上和原来的犯罪构成有一定差距，如果不做这种“以…论”就无法定罪，属于刑法中的特别规定

笔记中找这些讲得多的”以…论“

挪用公款罪

挪用的行为方式：（1）非法活动没有数额、盈利活动数额较大、其他活动数额较大超过三个人未还（2）归个人适用（区别于挪用特定款物罪），本身要记

受贿罪

关键在权钱交易（权力交易，用财产性利益），不论形式

拐卖妇女儿童罪

拐卖儿童罪 vs 拐骗儿童罪——直接看法条找区别。14周岁以下，骗不具有卖。

侵犯财产罪

罪名都是重要的，都考。

注意表述

交通肇事
负有照护职责人员性侵罪
事后抢劫【269】
挪用公款罪

罪状

空白、叙明、引证罪状、简单罪状

以危险方法危害公共安全罪

114兜底性条款（非刑法分则第二章的兜底条款）“以危险方法危害公共安全”要素：

（1）方法要客观上危险，无论主观认识错误（2）程度很严重，与法定刑配置要匹配（法定刑很高）：和防火、爆炸、决水……——看司法解释有哪些情形

组织出卖人体器官罪

看一眼 234之一增加的罪名
核心：被组织者同意，若不同意可能定义故意杀人/伤害罪
（“组织”罪：罪越重，对组织性的要求越高，即对被组织人员有控制性手段）

非法拘禁罪

本身的法律条文要注意
特别是都是被害人死亡的不同认定区别：结果加重、法律拟制、数罪并罚

侵犯公民个人信息罪

253之一来龙去脉前世今生

侵占罪

普通侵占 & 脱离占有物
脱离占有物中：侵占和盗窃的区别就在于归谁占有——行为人本人占有就是侵占，他人就是盗窃。
要注意“占有”的界定

危险驾驶罪

行为类型要掌握133四种类型

和交通肇事罪关系：危险驾驶罪（抽象危险犯）是交通肇事罪（实害犯）的前端[预防刑法观]，前者法定刑低于后者。

133构成其他犯罪的从一重处——包含交通肇事罪
概括性命题方式

以下贪污贿赂犯罪的说法，以下哪些说法是错误的？

多选题以重点的四章进行命题

人身、危害公共安全、财产、人身

名词解释20'

答题要求：只要答1句话，原则上就是送分的。

论述题（就是拿每一个大章节的名字来说，如危害公共安全罪与侵害公民人身权利罪与财产权利犯罪的关系）

公共安全就是人身权利和财产权利，只不过是特定多数人的权利。

考查罪与罪

非法拘禁和绑架的关系

行为主体、客体、具体行为差别

不仅仅是区别。还有关系：绑架以剥夺人身自由为前提，而剥夺人身自由以违背他人意志为前提。没有非法拘禁的行为不能定绑架。

考查评论性——开放性论述题

案例分析题（不唯一答案，言之有理即可）——集中在财产犯罪

构成侵占or盗窃的依据：法律规定（刑法文本有规定）、司法解释、法学理论
看法条

五章节刑法条文至少要看一遍，看得时候拿有色笔画一画

渎职只看397、399